DATOS DEL PROCESO ARBITRAL

NRO. DE EXPEDIENTE : EXP. NRO. 05-2023-MAMZ-CECARD/AYA.

MODALIDAD DE ARBITRAJE : Arbitraje Ordinario.

PARTES INTERVINIENTES :

Demandante : Hydroconsulting Ingenieros Asociados S.R.L.

Demandado : Municipalidad Distrital de Totos.

TRIBUNAL UNIPERSONAL : Abg. Marco Antonio Martínez Zamora – Árbitro Único.

SECRETARIA ARBITRAL : Bach. Katherine Sheyla Flores Martínez.

MATERIA DE CONTROVERSIA : Resolución de Contrato.

FECHA DE SOLICITUD : 11 de abril de 2023.

FECHA DE INSTALACION : 30 de mayo de 2023.

FECHA DE EMISION DE LAUDO : 12 de enero de 2024.

ESCRITOS POST LAUDO : Interpretación de Laudo.

Centro de Conciliación Arbitraje y Resolución de Disputas - CECARD

Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas - CECARD

EXPEDIENTE N°05-2023-MAMZ-CECARD/AYA

HYDRO CONSULTING INGENIEROS ASOCIADOS S.R.L - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOTOS

LAUDO DE DERECHO

DEMANDANTE: HYDRO CONSULTING INGENIEROS ASOCIADOS S.R.L,

DEMANDADO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOTOS

TIPO DE ARBITRAJE: Institucional, Nacional y de Derecho (encargado al Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas - CECARD).

TRIBUNAL ARBITRAL: Marco Antonio Martínez Zamora (árbitro único)

SECRETARIO ARBITRAL: Katherine Sheyla Flores Martínez

Enero de 2024

Centro de Arbitraje y Resolucion de Disputas - CECARD
RECIBIDO
12 ENE 2024
Nº de Registro: 16 Nº de Folios: 46
Hora: 13:13 Firma:
LA RECEPCIÓN NO ES SEÑAL DE CONFORMIDAD

Decisión N°18

En Lima, a los 12 días del mes de enero del año dos mil veinticuatro, el Tribunal Arbitral, luego de haber realizado las actuaciones arbitrales de conformidad con la ley y las normas establecidas, escuchados los argumentos sometidos a su consideración y deliberando en torno a las pretensiones planteadas en la demanda, dicta el siguiente laudo para poner fin, por decisión de las partes, a la controversia planteada

VISTOS

I. Contrato y convenio arbitral

1.1 La presente controversia, se encuentra referida al Contrato N°090-2022-MDT/GM (en adelante el Contrato), suscrito entre la Municipalidad Distrital de Totos (en adelante la Entidad o la demandada) y la empresa HYDROCONSULTING Ingenieros Asociados S.R.L. (en adelante el Contratista, la Empresa, el demandante), con el objeto de ejecutar la obra: "*MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PIEDRA BLANCA – WICHINKA EN EL CENTRO POBLADO DE CHACABAMBA, DISTRITO DE TOTOS, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO" CÓDIGO SNIP UNIFICADO N° 2317199*."

1.2. En virtud de la Cláusula Décima Octava del Contrato, por solicitud del Contratista y lo establecido en el artículo 226.2 del Decreto Supremo N° 344-2018-EF – Ley de Contrataciones del Estado y sus respectivas modificatorias; se estableció el ARBITRAJE INSTITUCIONAL, NACIONAL Y DE DERECHO, a competencia de la administración del Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas- CECARD, a sus Reglamentos y Lineamientos

II. Instalación del Tribunal Arbitral

2.1 Con fecha 17 de mayo de 2023 la Entidad, tras no recibir recusación alguna, quedó consentida la conformación del Tribunal Arbitral conformado por el Abogado Marco Antonio Martínez Zamora.

2.2 Mediante Resolución N°01 con fecha 30 de mayo de 2023, se instaló el procedimiento Arbitral, y se otorgó el plazo de cinco (05) días hábiles a partir del día siguiente de notificada la resolución a efecto que las partes manifiesten lo conveniente a su derecho.

III. SOBRE LA DEMANDA ARBITRAL

3.1. Con fecha 10 de julio de 2023, el Contratista presentó su escrito de demanda, con el petitorio que se expone a continuación:

> ***Primera pretensión principal:*** *Que se declare la Nulidad, Invalidez e Ineficacia de la Resolución de Gerencia N°006-2023-MDT/GM por la cual la Municipalidad de Totos resolvió el Contrato N°090-2022-MDT/GM.*

Segunda pretensión principal: *Que se declare que el avance parcial establecido en el calendario de avance de obra vigente es mayor al 80% del monto de la valorización acumulada programada a enero de 2023*

Tercera pretensión principal: *Se declare que la obra se encontraba paralizada del 01 al 24 de febrero de 2023, fecha en la que se notificó la resolución gerencial N° 006-2023-MDT/GM con la cual la Municipalidad Distrital de Totos resolvió el Contrato, por causas no atribuibles a la empresa, y por ellos se suspendió el plazo de ejecución de obra en el periodo ya mencionado del 01 al 24 de febrero.*

Cuarta pretensión principal: *Que se declare la inaplicabilidad de otras penalidades dispuesta por la Entidad por el monto S/. 214, 068.20; y a consecuencia de ello, la Municipalidad Distrital de Totos en caso de haber incurrido en penalidad reembolse dicho monto, al no haber respetado el debido procedimiento por incurrir en afectación al derecho a la defensa y/o contradicción; siendo que no son aplicables al contrato al no ser objetivas, ni razonables ni congruentes con el objeto del contrato.*

Primera pretensión subordinada a la segunda pretensión principal: *En cuanto el Tribunal Unipersonal considera que el avance parcial establecido en el calendario de avance de obra es menor del 80% del monto de la valorización acumulada programada a enero de 2023, se declare que el retraso es JUSTIFICADO en hechos no atribuibles a la empresa, y por tanto La Municipalidad Distrital de Totos no se encontraba habilitada a resolver el Contrato.*

3.2. Asimismo, se solicita que sea la Entidad, la que asuma la totalidad de los gastos arbitrales y costos incurridos.

3.3. Como antecedentes de su demanda, el Contratista sostiene lo siguiente:

3.4.1. El 19 de julio del 2022, la Entidad y el Contratista suscribieron el Contrato N°090-2022-MDT/GM, (de ahora en adelante el Contrato) por objeto la ejecución de la obra "Mejoramiento y ampliación del servicio de agua del sistema de riego Piedra Blanca Wichinka en el centro poblado de Chacabamba, distrito de Totos Cangallo - Ayacucho en un plazo de 240 días calendario.

3.4.2. Si bien la Entidad tiene como obligación esencial de entregar un expediente técnico sobre la descripción de las características y los requisitos funcionales para cumplir con la finalidad pública de la contratación y condiciones de ejecución, lo que a su vez permite a los postores formular ofertas adecuadas, de modo que, si el expediente no está correctamente formulado es imposible ejecutar la obra de modo debido y en los plazos establecidos. De este modo, correspondería a la Entidad subsanar y corregir cualquier deficiencia para viabilizar la ejecución y no se afecten los plazos.

3.4.3. Al respecto, el Contratista sostiene que el expediente era deficiente al tener información técnica, incorrecta, incompleta, incoherente e insuficiente. Para solucionar dicho problema, la Entidad habría aprobado el adicional y deductivo vinculante N°1 mediante Resolución de Alcaldía N° 111- 2022-MDT/A y, por tanto, la aprobación de un calendario de obra actualizado mediante Resolución de Alcaldía N° 112- 2022- MDT/A, este último el cual reemplazó al calendario de avance anteriormente aprobado mediante Resolución de Alcaldía N°103-2022-MDT/A.

3.4.4. Sin embargo, la Entidad decidió resolver el Contrato alegando demora injustificada en la ejecución, debido a la valorización acumulada ejecutada a enero de 2023 menor al 80% del monto acumulado programado en el calendario acelerado, conforme al informe de supervisión. Sin embargo, el demandante considera que dicha resolución fue arbitraria, por lo siguiente:

- No se habría tenido en cuenta que el calendario original, había sido sustituido por el aprobado mediante la Resolución de Alcaldía N° 112- 2022-MDT/A.
- El avance de obra es mayor al 80%
- Aún si fuera inferior al 80% el menor avance sería por hechos no imputables al Contratista.
- No se habría seguido el procedimiento establecido en el artículo 203.5 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por cuanto el supervisor no habría anotado en el cuaderno de obra que, al avance de lo valorizado, sería menor al 80% ni lo habría informado a la Entidad.

3.4.5. Refiere que en diciembre de 2022 y enero de 2023 ocurrieron lluvias en la zona de ejecución de la obra, las cuales incrementaron a finales del mes de enero; más aún SENAMHI reportó que las lluvias incrementaron en febrero y marzo. Frente a esta situación se solicitó la suspensión de la ejecución de la obra, lo cual no fue atendido, pese a ser técnicamente necesario. Así, sostiene que la obra fue paralizada desde el 01 de febrero de 2023 con la finalidad de no perjudicar su avance (que podría ser muy lento), · salvaguardar la integridad de los trabajadores y la propia obra; así, por este evento (la lluvia) el plazo de ejecución de obra debió suspenderse.

3.4.6. Asimismo, agrega que su parte había presentado la Valorización N°6 correspondiente a enero de 2023, siendo que antes de su pago, se les notificó la Carta N°053-2023-MDT-GM/RTM, con fecha 26 de mayo de 2023, por la cual se le comunica la imposición de "Otras penalidades" por el monto *SI* 214,068.20. Sobre este tema, refiere que el Contrato no establece el procedimiento para la imposición de "Otras penalidades", sino únicamente el procedimiento para su cobro, por lo que su imposición no sería válida.

3.4.7. Asimismo, sostiene que antes de recurrir al presente arbitraje, se planteó un proceso de conciliación, pese a lo cual la Entidad ni habría acudido ni habría efectuado el respectivo análisis costo beneficio, pese a que la Ley lo obliga a ello.

3.5. Como fundamentos de su demanda, el Contratista sostiene lo siguiente:

Respecto de la Primera Pretensión Principal

3.5.1. El 24 de febrero de 2023, se comunicó al Contratista mediante Carta N°001-2023-MDT-GM/RTM, que tenía como anexo la Resolución de Gerencia N°006-2023-MDT-GM la resolución total del Contrato, por las causales previstas en el art. 203.5 y en el literal b) del del acápite 164.1 del artículo 164° (concordante con el acápite 164.4 del artículo 164°) del del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en cuanto se deduce que, ante incumplimiento injustificado de obligaciones, el contrato puede resolverse con o sin requerimiento previo.

3.5.2. Para tales efectos, se tuvo en cuenta el artículo 203.5 de la Reglamento de ley de contrataciones del Estado, en cuanto señala que: "*Cuando el monto de la valorización acumulada es menor al 80% del monto acumulado programado del nuevo calendario, el inspector o el supervisor anota el hecho en el cuaderno de obra e informa a la Entidad. Dicho retraso puede ser considerado como causal de resolución del contrato o de intervención económica de la obra (...)*"

3.5.3. Alegan que la demora en el presente caso no es injustificada, puesto que como bien se ha indicado en el art. 203.5, la valorización acumulada ejecutada ha de ser menor al 80% del monto acumulado del nuevo calendario acumulado, supuesto que no ocurrió ya que debido a la aprobación de otro calendario de obra actualizado mediante la resolución N° 112- 2022- MDT/A de fecha 26 de octubre de 2022 en reemplazó del hasta ese momento vigente calendario acelerado.

En este sentido, desarrollan los diversos aspectos detallados en el acápite 3.4.4, destacando que la medición de avances debió efectuarse de acuerdo con el nuevo calendario, así como el incumplimiento de la formalidad relativa a la anotación del Supervisor de la obra del eventual retraso superior al 20%, afectando con ello su derecho al debido proceso.

3.5.4. Para ello, refiere que mediante Resolución de Alcaldía N°111-2022-MDT/A de fecha 17 de octubre de 2022, se aprobaron los expedientes técnicos de adicional de obra N°1-deductivo y el adicional vinculante N°1 que ampliaban partidas a ejecutar y, con ello dejó de regir el calendario acelerado.

3.5.5. Con la aprobación del nuevo calendario la Resolución N°112-2022-MDT/A, se dispuso la aplicación del art. 203.1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: "*En caso de retraso injustificado, cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada a una fecha determinada sea menor al 80% del monto de la valorización acumulada programada a dicha fecha, el inspector/supervisor ordena al contratista que presente dentro de 7 días siguientes, un nuevo calendario que contemple la aceleración de los trabajos*"

3.5.6. Así mismo se remiten al art. 203. 5 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en el que se dispone que se ha de anotar en el cuaderno la

circunstancia en cuestión y con ello salvaguardar los intereses del Contratista al viabilizar el cuestionamiento de la validez de la anotación. Si esto no ocurre, se transgrede el debido procedimiento, y por tanto todo acto derivado de la transgresión no puede generar la resolución del contrato.

Segunda pretensión principal

3.5.7. De acuerdo con el nuevo calendario, en el mes de enero se debió alcanzar un avance acumulado de 69.04% y un avance programado de 18.91% para el mes de enero.

3.5.8. La correspondiente al mes de enero, elaborada mediante carta N°09-2023/HCIA SRL/STR-TOTOS y mediante carta N° 10-2023/HCIA SRL/STR-TOTOS; reportó un avance mensual de 13.96% y un avance acumulado de 55.93% siendo el avance programado para enero un 69.04%. A razón de ello, para ese mes afirman se ejecutó el 81.01% del avance programado.

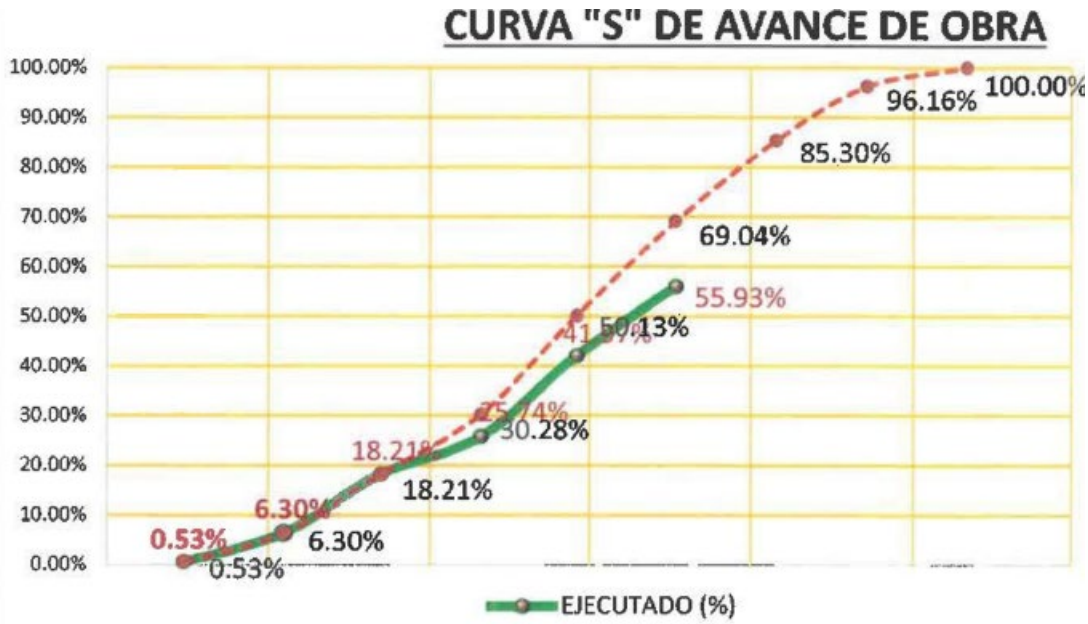
3.5.9. Se adjuntan en la demanda el cuadro N°01 de resumen de valorizaciones ejecutadas presentadas a la Entidad y el cuadro N°02 de control de Avance PROGRAMADO vs EJECUTADO.

CUADRO N°01: Resumen de Valorizaciones ejecutadas presentadas a la Entidad

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	AGOSTO 2022	SETIEMBRE 2022	OCTUBRE 2022	NOVIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2022	ENERO 2023
		16-31	01-30	01-31	01-30	01-31	01-31
COSTO DIRECTO	4 431 567.28	23 309.13	255 820.06	527 845.87	333 873.41	719 292.99	618 557.68
GASTOS GENERALES (11.00 %CD)	487 472.40	2 564.01	28 140.20	58 063.05	36 726.08	79 122.23	68 041.34
UTILIDAD (7.00 %)	310 209.71	1 631.64	17 907.40	36 949.21	23 371.14	50 350.51	43 299.04
SUB TOTAL	5 229 249.39	27 504.78	301 867.66	622 858.13	393 970.63	848 765.73	729 898.06
IGV	941 264.89	4 950.86	54 336.18	112 114.46	70 914.71	152 777.83	131 381.65
TOTAL	6 170 514.28	32 455.64	356 203.84	734 972.59	464 885.34	1 001 543.56	861 279.71
AVANCE MENSUAL		0.53%	5.77%	11.91%	7.53%	16.23%	13.96%
AVANCE ACUMULADO		0.53%	6.30%	18.21%	25.74%	41.97%	55.93%

CUADRO N°02: Control de Avance PROGRAMADO VS EJECUTADO

CRONOGRAMA			Ago-22	Set-22	Oct-22	Nov-22	Dic-22	Ene-23	Feb-23	Mar-23	Abr-23
PROGRAMADO	MENSUAL		0.53%	5.77%	11.91%	12.07%	19.85%	18.91%	16.25%	10.87%	3.84%
	ACUMULADO	0.00%	0.53%	6.30%	18.21%	30.28%	50.13%	69.04%	85.30%	96.16%	100.00%
EJECUTADO	MENSUAL	0.00%	0.53%	5.77%	11.91%	7.53%	16.23%	13.96%	0.00%	0.00%	0.00%
	ACUMULADO	0.00%	0.53%	6.30%	18.21%	25.74%	41.97%	55.93%			



3.5.10. Recalcan que el avance es mayor al 80%, lo cual es acreditable mediante la revisión de la 255 y el acta de constatación e inventario suscrito por la entidad y la Empresa el 01 de marzo de 2023. Por lo cual piden a este Tribunal que se declare fundada esta pretensión.

Primera pretensión subordinada a la Segunda pretensión principal

3.5.11. Señalan que, sin perjuicio de haber alcanzado más del 80% de ejecución de la obra según lo programado hasta enero, el retraso que impidió el avance programado proviene de acontecimientos tales como las lluvias entre diciembre 2022 y enero 2023, los que habrían sido ajenos a la voluntad de la empresa y, por tanto, fuera de su responsabilidad. Refieren que en el cuaderno de obra, tanto de las anotaciones del residente y el supervisor, se demuestra que las lluvias constantes retrasaron la ejecución programada y por tanto de existir el retraso, estaría justificado.

3.5.12. Por ello, adjuntan las anotaciones hechas en el cuaderno de obra, en las cuales, los asientos N°169, N°185, N°187, N°189, N°193, N°195, N 207, N°209, N°213 y, de la misma manera, hasta el asiento N°254 en cual finalmente se señala que estas precipitaciones suelen presentarse entre noviembre y diciembre, siendo que las mismas impiden llegar a las metas programadas en el día. Con estos asientos afirma que se acredita la presencia de lluvias que perjudicaron la ejecución de los trabajos programados, retrasándolos.

Por su parte, en los asientos N°176 y N°178, refiere que acredita la paralización de los trabajos, debido a la falta de abastecimiento ocasionado por la paralización de las carreteras a causa de las protestas violentas acontecidas acontecida el día 15 de diciembre de 2022, por lo cual recién se reactivó el día 17 de diciembre de 2022.

3.5.13. Si bien las lluvias no suelen generar ese tipo de atrasos, sostiene que, en esta ocasión tuvo tal efecto, puesto que la constancia de las precipitaciones produjo la saturación del terreno con humedad excesiva lo que imposibilitó la

utilización de concreto para ejecución de la obra de canales, y más aún se generó un riesgo para la integridad de los trabajadores, por las constantes descargas eléctricas (rayos) acaecidos en la zona.

Tercera Pretensión Principal

3.5.14. Teniendo en cuenta las fuertes lluvias acontecidas entre diciembre 2022 y enero 2023, se presumió mayores precipitaciones entre enero y marzo como suele ocurrir en la sierra del país, así mismo afirman se tuvo en cuenta los reportes emitidos por SENAMHI sobre el incremento de precipitaciones, como habría terminado ocurriendo.

3.5.15. A razón de lo anterior, decidieron paralizar la obra el 01 de febrero de 2023, alegando que ejecutar la obra en dichas condiciones era perjudicial - tanto para el avance de la obra - como para la integridad de los trabajadores. Además, acotan que, por dicha paralización, se debe considerar suspendido el plazo de ejecución en todo efecto.

3.5.16. Afirman que a paralización iniciada el 01 de febrero de 2023 fue acreditada tanto en el asiento 255 del cuaderno de obra, como en el Acta de Acuerdo que decidió paralizar la obra a partir del día 03, pactado entre autoridades de la comunidad de Chacabamba, el representante de la municipalidad de Totos, el alcalde Wilson Retamozo Gálvez, el jefe de supervisión Ang, Amílcar Juárez Choque y un representante de la Empresa contratista. Por ende, refieren que la obra estuvo paralizada hasta el 24 de febrero de 2023, con ocasión de la resolución del contrato.

Cuarta Pretensión Principal

3.5.17. La Entidad mediante Carta N°053-2023-MDT-GM/RTM del 26 de mayo de 2023, remitió el sustento de penalidad a cobrar cuando se ejecute el pago de la valorización N°06 del mes de enero del 2023, adjuntando el Informe N°01-2023-MDT/SGDU-SFLL del Subgerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano, así como la Carta N°013-2023-WARI Consultores/Chacabamba/LCE-RL emitida por la Supervisión.

3.5.18. En los Informes se señala las penalidades serán aplicables; I) en ausencia de profesionales en obra durante los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2022, y enero 2023; II) Por no dotar de EPP al personal durante los días 10 de diciembre de 2022 y 6 de enero de 2023, calculándose tal penalidad en la suma de S/.214,068.20.

3.5.19. En esa línea, el demandante se remite a los Art. 161 y 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado sobre la aplicación de penalidades en cuanto señala lo siguiente:

> "***Articulo 161. Penalidades***
>
> *161.1. El contrato establece las penalidades aplicables al contratista ante el Incumplimiento Injustificado de sus obligaciones contractuales a partir de la*

información brindado por el área usuario, las mismas que son objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria."

"***Articulo 163 Otras penalidades***

163.1. Los documentos del procedimiento de selección pueden establecer penalidades distintas a fa mencionada en el artículo 162, siempre y cuando sean objetivos, razonables, congruentes y proporciona/es con el objeto de la contratad6n. Para estos efectos, incluyen los supuestos de aplicación de penalidad, distintas al retraso o mora, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y et procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar."

3.5.20. Al respecto, consideran que la cláusula décima tercera del contrato sobre la aplicación de "***otras penalidades***" es ilegal pues no respeta los parámetros establecidos en el art. 163 del Reglamento de la ley de contratación del Estado, respecto a los criterios de objetividad, razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

3.5.21. Alegan que ninguno de los supuestos de aplicación contemplados en la cláusula contractual es enteramente objetivo, en cuanto el procedimiento de verificación de incumplimientos ha sido establecido según informe del supervisor de obra y/o subgerente de infraestructura y desarrollo urbano; lo cual, señalan, implica que el procedimiento es deficiente al no establecer plazos para la generación del informe, ni el contenido mínimo, ni dispone traslado de imputaciones a la empresa para su descargo o subsanación a los incumplimientos imputados como garantía del derecho de defensa.

3.5.22. También afirman que la cláusula contradice el derecho al debido proceso presente en el Art.139.3 de la Constitución; al no haberse establecido métodos idóneos para demostrar los incumplimientos por parte del contratista que sustenten los citados informes, lo cual genera indefensión del Contratista, frente a un abuso de la posición contractual por parte de la Entidad, quien señala la empresa, no observó el principio anterior, así como la lealtad y buena fe contractual.

3.5.23. El Informe, al ser establecido como "***procedimiento***", debe estar en el marco del respeto irrestricto a la buena fe contractual y la lealtad recíproca de las partes; y por tal proscribe la vulneración al derecho de debido procedimiento sobre la aplicación de penalidades. Así, alega que el debido procedimiento supone que la Empresa ostente el derecho a la contradicción y defensa mediante absolución; lo que implica la debida claridad, motivación y prueba de los hechos que fundamenta la imputación, lo que consideran que no ocurrió en el presente caso.

Por otro lado, señalan que el monto fijado como penalidad no es proporcional a la gravedad del incumplimiento en cuanto excedan el propio costo del objeto a cumplir.

3.5.24. Recalca que la finalidad de establecer penalidades es desincentivar el incumplimiento del Contratista y resarcir a la entidad por los posibles perjuicios a causa de Incumplimiento. Por tal, afirman que es incongruente que, tras 10

meses de ejecución de obra, recién se advierta de un incumplimiento de presencia de profesionales durante los meses anteriores, habiendo aprobado valorizaciones y emitido su conformidad sin penalidades durante agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2022.

3.5.25. Sobre lo anterior, señala que la empresa no fue notificada ni por la Supervisión ni por la Entidad, respecto al incumplimiento de obligaciones por ausencia de profesionales en los meses consignados, y por lo cual no hubo posibilidad de tomar acciones correctivas. De ello, sostiene que se configura la falta de veracidad, arbitrariedad y abuso de autoridad con la aplicación de la penalidad aludida.

3.5.26. Del mismo modo, sostiene que no fueron notificados de incumplimiento alguno, sino que en los respectivos informes mensuales de valorización de los meses agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2022, y enero del 2023, se adjuntaron conformidades de la supervisión más conformidades de pago que evidencian que el Contratista no incurrió en causales de penalidad. Frente a ello, el contratista expresó su extrañeza mediante la carta N°053-2023-MDT-GM/RTM con fecha 26 de mayo en respuesta a la comunicación de la penalidad que tan solo adjuntó el cálculo de monto sin ningún parámetro de verificación del supuesto penalizado.

3.5.27. Por tales razones, alegan que conforme a la Opinión N° 052-2022/DTN del OSCE de fecha 14 de julio del 2022, la aplicación de la penalización es arbitraria e injustificada al carecer de veracidad el supuesto a penalizar, en cuanto señala lo siguiente: "*2.3.1 (...) si en los documentos del procedimiento de selección no se ha contemplado el procedimiento a seguir para verificar la configuración del supuesto que dará lugar a la aplicación de "otras penalidades", dicha penalidad no podrá ser aplicada al contratista*"

IV. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

4.1. Con fecha 02 de agosto de 2023, la Entidad remitió el escrito con sumilla "***Contestación de la demanda***", solicitando que se declare infundadas las pretensiones planteadas por su contraparte, sobre la base de lo se expone en los acápites siguientes.

Respecto a la primera pretensión principal

4.2.1 En atención a los hechos ya narrados, y tras el apercibimiento del retraso injustificado del Contratista invocan el Art. 203.4 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

> "*el nuevo calendario no exime al contratista de la responsabilidad por demoras injustificadas, ni es aplicable para el cálculo y control de reajustes ni para sustentar las solicitudes de ampliaciones de plazo*",

4.2.2. Sobre lo dicho por el demandante, que la Entidad incurrió en una decisión arbitraria, abusiva e ilegal de resolver el contrato, causando un perjuicio

económico a la Empresa; la Entidad alega que se ha cumplido todos los requisitos y el debido procedimiento legal, administrativo y técnico.

4.2.3 La Carta N.º 011-2023-WARI CONSULTORES/CHACABAMBA/LCE-RL, con fecha de ingreso el 13 de febrero 2023, incluyó un resumen ejecutivo de la valorización N° 06 de enero de 2023, que informa en el capítulo X. CONCLUSIONES:

CAPITULO X.- CONCLUSIONES.

- ✓ Como se puede observar el avance pago de supervisión de obra por tantas es de **12.92 %.** en el presente mes de **Enero del 2023.**
- ✓ El pago correspondiente al presente mes por concepto de supervisión es de S/. **34,687.85.**
- ✓ La amortización de adelanto directo por supervisión es de **S/. 0.00**
- ✓ El monto a pagar por supervisión en el presente mes es de **S/. 34,687.85.**
- ✓ La ejecución de la obra se inicia el 16 de Agosto del 2022: a la fecha con respecto al cronograma de avance de obra reprogramado, los trabajos en obra se encuentran ATRASADOS. **incurriendo por 2da vez en retraso injustificado se sugiere a la entidad aplicar el Art 203.5.** (cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada es menor al ochenta por ciento (80%) del monto acumulado programado del nuevo calendario, el inspector o el supervisor anota el hecho en el cuaderno de obra e informa a la Entidad. Dicho retraso puede ser considerado como causal de resolución del contrato o de intervención económica de la obra, no siendo necesario apercibimiento alguno al contratista de obra)
- ✓ Los reajustes para el presente mes no se aplicaron, por lo que el mismo se realizara la corrección en la liquidación de supervisión, conforme establecen los REAJUSTE DE LOS PAGOS, según el procedimiento y las fórmulas monómicas, de acuerdo a lo previsto en el numeral 38.5 del artículo 38 del Reglamento.

4.2.4. Similarmente, el Informe N°013-2023-MDT/SGIDU-SFLL de fecha 17 de enero 2023 emitido por el subgerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Totos habría informado lo siguiente:

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. La ejecución de la obra se inicia el 16 de agosto del 2022, a la fecha con respecto al cronograma de avance de obra reprogramado, los trabajos en obra se encuentran **ATRASADOS**.

CRONOGRAMA		VALORIZACIÓN 01 AGOSTO 2022	VALORIZACION 06 ENERO 2023
PROGRAMADO	MENSUAL	1.83%	18.91%
	ACUMULADO	1.83%	69.04
EJECUTADO	MENSUAL	0.53%	7.95%
	ACUMULADO	0.53%	49.92%
PORCENTAJE		0.29%	0.72%

2. La Valorización N° 01 correspondiente al mes de agosto del 2022, presentada por el Contratista **HYDROCONSULTING INGENIEROS ASOCIADOS SRL – HCIA S.R** el Contratista tiene un retraso injustificado a su calendario de ejecución de obra siendo lo programado de 1.83% y habiendo sólo ejecutado el 0.53% teniendo un retraso mensual de 1.3%, por el que se solicitó un CAOV.

3. La valorización N° 06 correspondiente al mes de ENERO 2023, presentada por el Contratista **HYDROCONSULTING INGENIEROS ASOCIADOS SRL – HCIA S.R.L.** el Contratista tiene un retraso injustificado a su calendario de ejecución de obra siendo lo programado de **18.91%** y habiendo sólo ejecutado el **7.95%**, teniendo un retraso mensual de **10.96%**.

4. El porcentaje acumulado programado es **69.04%** en el último CAOV aprobado, el contratista a la fecha de enero 2023, siendo su porcentaje acumulado de sólo el **49.92%**; calculando el porcentaje de avance del 49.92 % /69.04 % = 0.72% no llegando al **80%** en el porcentaje acumulado de la obra.

CRONOGRAMAS		Ago-22	Set-22	Oct-22	Nov-22	Dic-22	Ene-23	Feb-23	Mar-23	Abr-23
PROGRAMADO	MENSUAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	ACUMULADO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
EJECUTADO	MENSUAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
	ACUMULADO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			

8. Cabe indicar que al ser la **SEGUNDA VEZ** que el contratista tiene **RETRASO INJUSTIFICADO**; de acuerdo a los análisis y antecedentes que obra en el acervo documentario en la entidad, por lo tanto **RESOLVER DE FORMA TOTAL** el **Contrato N° 090-2022-MDT/GM** derivado de la Licitación Pública N° 002-2021-GR CAJ – Primera Convocatoria; suscrito entre la **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOTOS** y la Señora Sussy Torres Ramos – Gerente General de la empresa **HYDROCONSULTING INGENIEROS ASOCIADOS S.R.L.**; cuyo objeto es la ejecución de la obra denominada: "**MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVIMIOS DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PIEDRA BLANCA WICHINKA EN EL CENTRO POBLADO DE CHACABAMBA DISTRITO DE TOTOS CANGALLO AYACUCHO COD SNIP 2317199**", de acuerdo al Art. 203.5 del reglamento de la Ley Contrataciones del Estado.

9. Con referencia a la aplicación de las **PENALIDADES** que pudiera haber incurrido el contratista de acuerdo a su contrato suscrito con la entidad, durante los meses que viene ejecutando se solicita a la supervisión la verificación y emita un informe con la cuantificación y verificación de los mismo en el término de la distancia de acuerdo a Ley.

En todo cuanto informo para su conocimiento y fines convenientes.

Atentamente,

C.C.C.C.
ARCH / SFLL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOTOS
ALCALDE - AYACUCHO
Ing. Sergio Flores Llantay

4.2.5 Por último, la Opinión Legal N°004-MDT/ALE/PJT, con fecha 22 de febrero del 2023, emitido por el asesor legal de la Municipalidad Distrital de Totos, informa de lo siguiente:

IV.- CONCLUSIONES:

Estando a todo lo señalado y siendo absolutamente objetivo y respetuoso de la normatividad existente señalada en los considerandos normativos, es mi **OPINION LEGAL.**

PRIMERO.- DECLARAR, procedente el presente informe emitido por el Subgerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Totos, a fin de **RESOLVER** el **CONTRATO N° 090 – 2022 - MDT/GM**, celebrado con la **EMPRESA HYDROCONSULTING INGENIEROS ASOCIADOS SRL**, para la ejecución de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PIEDRA BLANCA WICHINKA EN EL CENTRO POBLADO DE CHACABAMBA - DISTRITO DE TOTOS - CANGALLO - AYACUCHO"**, con **CUI N° 2317199**, en conformidad al numeral 203.5., del articulo 203°, previsto en el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 344 – 2018 – EF.

SEGUNDO.- REMITIR, a la Gerencia Municipal de la Municipalidad Distrital de Totos, para que **PROCEDA a RESOLVER** mediante **ACTO RESOLUTIVO** el **CONTRATO N° 090 – 2022 - MDT/GM**, celebrado con la **EMPRESA HYDROCONSULTING INGENIEROS ASOCIADOS SRL**, para la ejecución de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PIEDRA BLANCA WICHINKA EN EL CENTRO POBLADO DE CHACABAMBA - DISTRITO DE TOTOS - CANGALLO - AYACUCHO"**, con **CUI N° 2317199**, en conformidad al numeral 203.5., del articulo 203°, previsto en el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 344 – 2018 – EF.

TERCERO.- RECOMENDAR, ala Gerencia Municipal de la Municipalidad Distrital de Totos, que una vez se **RESUELVA**, el presente **CONTRATO N° 090 – 2022 - MDT/GM**, **REMITA** mediante **CARTA NOTARIAL**, la presente disposición al Gerente General de la empresa **HYDROCONSULTING INGENIEROS ASOCIADOS SRL.**

4.2.6 Teniendo en cuenta lo anterior, se habría emitido la Resolución Gerencial N°006-2023-MDT/GM, de Resolución Contractual, la cual fue comunicado al Contratista mediante Carta N°001-2023-MDT/GM de fecha 23 de febrero del 2023; atendiendo a lo establecido en el Art.165.4 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado:

> *"En estos casos, basta comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato"*

Similarmente se dispone en el 203.5 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

> *"dicho retraso puede ser considerado como causal de resolución del contrato o de intervención económica de la obra, no siendo necesario apercibimiento alguno al contratista de obra".*

4.2.7 A partir de todo lo anterior mencionado, la Entidad afirma que atención correctamente todas las formalidad y necesidades del debido proceso, resolvió el contrato razonablemente conforme a argumentos facticos y legales.

Contestación a la Segunda pretensión principal

4.2.8 Alegan que todo tipo de demora es responsabilidad de la Empresa contratista y por tanto se remiten al Art. 203.4, antes ya mencionado, por lo cual, la supervisión mediante carta N°011-2022-WARI CONSULTORES/CHACABAMABA/LCE-RL, con fecha 13 de febrero de 2023, dio

a conocer a la Entidad sobre el retraso, por cual remite al ya mencionado art. 203.5 sobre que el retraso injustificado configura casual de resolución contractual. Así mismo recalcó que, mediante Carta N°019-2023-WARI CONSULTORES/Chacabamba/LCE - RL de fecha 28 de febrero, no tenía acceso al cuaderno de obra y para ello adjuntan la siguiente imagen:

WARI CONSULTORES E.I.R.L.

CARGO

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

MESA DE PARTES 28 FEB 2023

CARTA Nro. 019-2023- WARI CONSULTORES/CHACABAMBA/LCE-RL

Ayacucho, 28 de febrero de 2023.

Señores:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOTOS – CANGALLO – AYACUCHO.

ASUNTO : COMUNICO NEGATIVA DE ACCESO AL CUADERNO DE OBRA HASTA LA FECHA.

Referencia : a) CARTA N° 018-2023-WARI CONSULTORES/CHACABAMBA/AJCH-JS.
b) CONTRATO N° 066-2022-MDT/GM. – Supervisión de obra
SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PIEDRA BLANCA – WICHINKA EN EL CENTRO POBLADO DE CHACABAMBA, DISTRITO DE TOTOS – CANGALLO – AYACUCHO", CON CODIGO PIP N° 2317199.

Estimados señores:

El suscrito, Representante Legal de WARI CONSULTORES E.I.R.L. mediante la presente, remito la CARTA Nro. 18-2023-WARI CONSULTORES/CHACABAMBA/AJCH-JS, donde informa que la empresa contratista HYDROCONSULTING INGENIEROS ASOCIADOS S.R.L. no permite el acceso al cuaderno de obra desde el 01 de febrero hasta la fecha.

Se adjunta:
⇒ Copia de CARTA N° 018-2023-WARI CONSULTORES/CHACABAMBA/AJCH-JS.

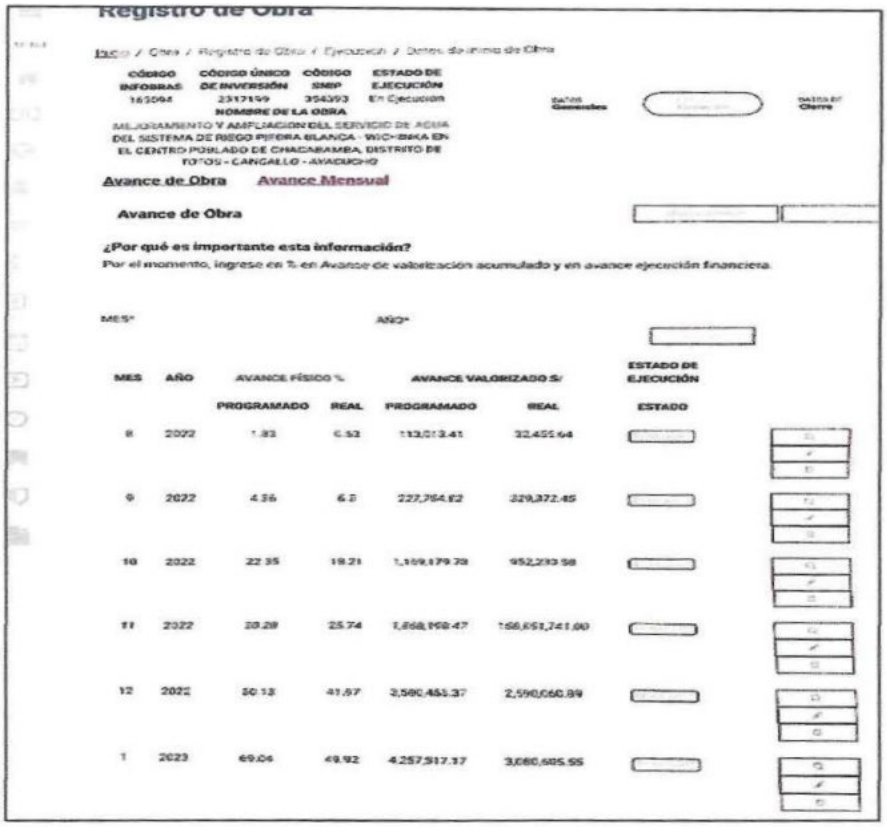
Sin otro particular y en espera de su pronta atención, nos suscribimos de ustedes

Atentamente.

4.2.9 Sobre lo dicho por la empresa, respecto a que la obligación de la Entidad es entregar al Contratista un expediente técnico que contengan descripción objetiva y demás para cumplir con la finalidad pública de la contratación y las condiciones en las que se ejecuta a razón de lo dicho en el art. 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

4.2.10 Sobre ello, indican que luego de firmado el Contrato y en la primera semana de ejecución de obra, se realizó entre la Municipalidad y el Contratista el INFORME DE COMPATIBILIDAD, en el cual se determinó que el expediente técnico original era deficiente, por el cual se aprobó el expediente técnico deductivo adicional de obra N°01 y deductivo - adicional vinculante N°01 que permitió la aprobación del calendario actualizado como ya se relató anteriormente, y que terminó por reemplazar al calendario acelerado de obra aprobado en la Resolución de Alcaldía N°103-2022-MDT/A.

4.2.11 Se comprueba entonces que, tras el reemplazo del calendario acelerado, no se afectó en nada al Contratista para el avance de obra, en cuando los adicionales han generado ampliación de plazos. Más bien, señalan que fue responsabilidad del Contratista el retraso de ambas ocasiones, para lo cual adjuntan el registro de INFOBRAS sobre dicho tema, como se aprecia a continuación:



Registro de Obra

Inicio / Obra / Registro de Obra / Ejecución / Datos de Inicio de Obra

CÓDIGO INFOBRAS	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN	CÓDIGO SNIP	ESTADO DE EJECUCIÓN
163094	2317199	354393	En Ejecución

NOMBRE DE LA OBRA

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PIFERA BLANCA - WICHINKA EN EL CENTRO POBLADO DE CHACABAMBA, DISTRITO DE FOTOS - CANGALLO - AYACUCHO

Datos Generales

Datos de Obra

Avance de Obra Avance Mensual

Avance de Obra

¿Por qué es importante esta información?

Por el momento, ingrese en % en Avance de valorización acumulado y en avance ejecución financiera.

MES* AÑO*

MES	AÑO	AVANCE FÍSICO % PROGRAMADO	AVANCE FÍSICO % REAL	AVANCE VALORIZADO S/ PROGRAMADO	AVANCE VALORIZADO S/ REAL	ESTADO DE EJECUCIÓN ESTADO
8	2022	1.83	0.53	113,013.41	32,455.64	
9	2022	4.36	6.0	227,764.82	329,372.45	
10	2022	22.35	19.21	1,169,179.70	952,293.58	
11	2022	30.28	25.74	1,868,958.47	1,566,651,741.00	
12	2022	50.13	41.67	2,580,453.37	2,590,060.89	
1	2023	69.04	49.92	4,257,917.17	3,080,605.55	

4.2.12 Siendo así, al considerar la parte demandante que expediente técnico estaba mal formulado y, por tanto, se aprobaron los respectivos adicionales; se estaría reconociendo que no se superó el 80% de las valorizaciones programadas a enero de 2023. Así mismo, tal hecho estaría reconocido en su prestación subordinada, pero según ellos, hay justificación de ello por acontecimientos no atribuibles a su responsabilidad

Más aún el demandante presentó la factura de la valorización de S/,310,154.35 de enero de 2023, y por lo cual se demuestra que no ejecutó más del 80% programado, puesto que la Empresa inicialmente facturó S/. 598,562.56 aduciendo que no superaron el 80% de la valorización N°06

Primera pretensión subordinada a la segunda pretensión principal

4.2.14. Afirma la Entidad que, si bien en el cuaderno de obra se señalan las lluvias acontecidas en la zona de obra, alegar tal situación como causal de paralización es por lo menos ambiguo, puesto que en dicha zona suele llover constantemente.

En consecuencia, señalan que la Empresa siempre tuvo conocimiento, y aún con ello decidieron no seguir un procedimiento regular de suspensión obra, sino que no ejecutaron la obra queriendo eximirse de responsabilidad, por lo cual han de asumir la responsabilidad como bien señala el art. 203.4 sobre demoras injustificadas.

4.2.15 Como ya señalaron, el nuevo calendario no exime de responsabilidad al contratista por demoras injustificadas; por ello que el Supervisor de obra

decidió informar a la Entidad, la cual, frente al retraso, decidió resolver el contrato sin necesidad de requerir apercibimiento alguno al contratista.

4.2.16 Además alegan que el Contratista, al formular su segunda opción de pretensión admite que no superó el 80%, por causales ajenas a su responsabilidad; sin embargo, esto corrobora que no se llegó al monto de la valoración programado a enero de 2023.

Contestación a la Tercera Pretensión Principal

4.2.17 Frente a la afirmación del demandante sobre que la obra estaba paralizada del 01 al 24 de febrero de 2023, sin embargo, la Entidad alega que, mediante la carta N°021-2023-WARI CONSULTORES CHACABAMBA/LCE-RL de fecha 10 de marzo de 2023 en la que se remitió el Informe de Avance de Obra correspondiente a la valorización N°07; se observa un avance del 4.51%, y por tal adjuntan la siguiente imagen:

RESUMEN DE VALORIZACION
MES DE FEBRERO DEL 2023
SIN REAJUSTE

OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PIEDRA BLANCA – WICHINKA EN EL CENTRO POBLADO DE CHACABAMBA, DISTRITO DE TOTOS – CANGALLO - AYACUCHO"

CONTRATISTA : HIDROCONSULTING INGENIEROS ASOCIADOS SRL.
RESID. DE OBRA : ING. EDSON ADRIAN SEVERINO HUAPAYA
SUPERVISION : WARI CONSULTORES EIRL.
SUPERVISOR : ING. AMILCAR JUAREZ CHOQUE

DESCRIPCION	ACUMULADO ANTERIOR (S/.)	AVANCE ACTUAL (S/.)	ACUMULADO ACTUAL (S/.)	SALDO (S/.)
1) VALORIZACION CONTRACTUAL	2,610,682.67 49.92%	235,714.21 4.51%	2,846,396.88 54.43%	2,382,852.51 45.57%
2) REINTEGROS Fórmula Polinómica Unica	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	
3) VALORIZACION BRUTA (1) + (2)	2,610,682.67	235,714.21	2,846,396.88	
4) AMORTIZACIONES Y DEDUCCIONES Y OTROS	675,656.17	86,680.30	762,336.47	283,513.40
AMORTIZACIONES	675,656.17	86,680.30	762,336.47	283,513.40
Adelanto Directo	0.00	0.00	0.00	-
Adelanto Materiales	675,656.17	86,680.30	762,336.47	283,513.40
DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
Adelanto Directo	0.00	0.00	0.00	-
Adelanto Materiales	0.00	0.00	0.00	-
5) VALORIZACION NETA (3) – (4)	1,935,026.50	149,033.91	2,084,060.41	
6) IGV (18 % DE (3) – (4))	348,304.77	26,826.10	375,130.87	
7) MONTO TOTAL A CANCELAR (5) + (6)	2,283,331.27	175,860.01	2,459,191.28	

AVANCE COMPARATIVO GENERAL

AVANCE DE OBRA	PROGRAMADO AL 28 DE FEBRERO DE	10.25%	CUM PROGRAM	85.38%
	EJECUTADO AL 28 DE FEBRERO DEL 2	4.51%	CUM EJECUTAD	54.43%

Página 1

4.2.18 Recalcan que mediante la Carta N°033-2023-WARI CONSULTORES CHACABAMBA/LCE-RL del 16 de mayo de 2023, se informó que la empresa contratista no ha suspendido sus actividades durante el mes de febrero del 2023 y se adjuntó fotografías fechadas y cuatro actas de constatación de la realización de diferentes trabajos de febrero (fotografías y constataciones presentes en la página 12-14 del escrito de contestación de demanda). Similarmente con fecha 02 de mayo de 2023 se presentó un memorial de solicitud de pago de honorarios de los obreros correspondiente a enero y febrero de ese año

MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO
CHACABAMBA - TOTOS

08 MAY 2023
Exp. N° 0504 Folio 01
Hora: 12:59 p.m. Firma:

Chacabamba, 02 de Mayo de 2023.

MEMORIAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOTOS
MESA DE PARTES
04 MAYO 2023
Exp. N° 279 Folio: 14
Hora: 12:09 Firma:

SEÑOR:

WILSON RETAMOZO GALVEZ
ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO DE TOTOS

Los suscritos beneficiarios de la comunidad Chacabamba con la ejecución del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PIEDRA BLANCA-WICHINCA, EN EL CENTRO POBLADO DE CHACABAMABA, DISTRITO TOTOS, CANGALLO, AYACUCHO", nos dirigimos a Ud. muy respetuosamente y exponemos.

4.2.19 Sobre la paralización de la obra, el demandante afirmó que se inició desde 01 de febrero del 2023 por las causales previamente explicadas; por otro lado, la Entidad alega que una suspensión de obra ha de cumplir el procedimiento señalado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que establece que se debe empezar con la "anotación de suspensión" en el cuaderno de obra y adjuntarse los suficientes medio probatorios para posterior entrega al Supervisor, quien mediante una pre evaluación que determina la conformidad o negativa de la solicitud, mediante una opinión legal de la propia Entidad para emitir o no la RESOLUCIÓN DE SUSPENSIÓN DE OBRA.

4.2.20 Por lo anterior, afirman que no se dio lugar a un correcto procedimiento en cuanto la Carta N°006-2023-WARI CONSULTORES CHACABAMBA/LCE-RL, se informó que el documento presentado por la Empresa tenía observaciones recién subsanadas por segunda vez, el 20 de febrero por la Empresa.

4.2.21 Esto afirman, corrobora que la Entidad no negó la solicitud de suspensión, sino que la empresa no presentó la justificación técnica requerida. A pesar de ello, el contratista anotó unilateralmente una suspensión en el asiento N°255 con fecha 01 de febrero de 2023 sin contar con la firma de la Supervisión, más aún, teniendo en cuenta que tenían conocimiento del procedimiento de suspensión de obra, que requiere no solo una anotación en el cuaderno de obra, sino una solicitud documentada y debidamente probada hacia los órganos competentes integrantes del contrato.

4.2.22 Puntualizan que en el asiento N°256 del primero de marzo, se evidencia que la Supervisión informó que no tuvo acceso al cuaderno de obra desde el 01 de febrero; situación que fue puesta a conocimiento de la Entidad mediante carta N°019-2023-WARICONSULTRES/CHACABAMBA/LCE-RL.

4.2.23 Respecto a lo dicho por el demandante sobre el Acto de acuerdo de la sequía Piedra Blanca del 3 de febrero; la Entidad alega que, de acuerdo al regular procedimiento de suspensión de obra, el demandante introdujo documentos y actas fuera de lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado, y por lo cual no son válidos para la formalidad del caso; además señalan que

4.2.24 Sobre la reunión en la que se celebró la firma del acta, puntualizan que ni fue convocada por la Municipalidad Distrital de Totos ni por algún representante de la Empresa contratista, sino por el Alcalde del centro poblado de Chacabamba; con lo cual, no hubo participación técnica de la entidad ni del contratista, dicho ello precisan que el Ing. JOSE GOTEA ZAMBRANO no ha sido acreditado con ningún documento ante la Entidad, tampoco existe en algún cargo directivo como representante legal ni como socio en la constitución de la empresa lo cual no impidió a los asistentes el paralizar la obra el día 03 de febrero hasta el 20 de marzo de 2023. Ciertamente, esto contraría lo declarado por el demandante sobre que la paralización inició el día 01 de febrero hasta el 24 del mismo mes.

Contestación a la cuarta pretensión de la demanda

4.2.25 Respecto a la Carta N°013-2023-WARI CONSULTORES/CHACABAMBA/LCE-RL, con fecha 16 de febrero 2023 emitida por la Supervisora de obra que indica el monto de la penalidad a aplicar por un monto de S/. 214.068.20; alegan que dicha penalidad se sustenta a razón de lo dicho en los informes N°021-2023-MDT/SGIDU-SFLL y N.° 034-2023-MDT/SGIDU/JLPS emitidos por la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Totos; y en la OPINIÓN LEGAL W 011-2023-MDT/ALE/PJT, con fecha 12 de junio del 2023, emitido por el Asesor Legal Externo de la Municipalidad Distrital de Totos en la que alegó;

> **CONCLUSION.**
>
> Que, estando al sustento legal expuesto en los considerandos que preceden, respecto al pago correspondiente a la valorización N° 06 del mes de enero del 2023 a la empresa HYDROCONSULTING INGINIEROS ASOCIADOS S.R.L., **OPINA:**
>
> **Se recomienda reconocer** el pago por el monto de **S/. 96,086.15 (NOVENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y SEIS SOLES CON 15/100)** (descontando las penalidades advertidas en el informe Nº 034-2023-MDT/SGIFU/JLPS), correspondiente a la valorización N° 06 del mes de enero del 2023 de la Obra: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PIEDRA BLANCA WICHINKA, EN EL CENTRO POBLADO DE CHACABAMBA, DISTRITO DE TOTOS, PROVINCIA DE CANGALLO – AYACUCHO; ello, en conformidad del numeral 161.4 del Artículo 161° y numeral 196.1 del Artículo 196° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

4.2.26 Precisan que la penalidad se aplica sobre las valorizaciones N°1 a la N°06 por lo ocurrido con los EPP (equipos de protección personal) con la suma de S/. 2,468.20, y por ausencia de personal clave con suma de S/. 211,600.00, que a la fecha recién se ejecutó Art.161 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

4.2.27 Sobre lo dicho por el demandante respecto a la vulneración de un derecho a defensa, la Entidad alega que sí comunicó al Contratista, mediante la carta

N°053-2023-MDT-GM/TnM de fecha 17 de mayo del 2023. De la misma forma niega lo dicho por el demandante sobre que la Entidad no se apersonó a las citas de conciliación, en cuanto afirman que sí acudieron a todas las citas como se evidencia en el ACTA DE CONCILIACIÓN N°10-2023-CC-CECARD/AYA, en el expediente N.° 09-2023 por la cual no se llegó a acuerdo alguno con la empresa, y en el ACTA DE CONCILIACIÓN N°13-2023-CC-CECARD/ AYA del expediente N.°14-2023 en la que se explicó que no se asistió al proceso de conciliación por estar fuera del plazo.

4.2.27 Concluye señalando que no asumirá ningún gasto propuesto por la demandante; y más bien se declara infundada la primera pretensión principal, la segunda pretensión principal; la primera pretensión subordinada a la segunda pretensión principal y la tercera y cuarta pretensiones principales.

V. FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS Y ACTUACIÓN DE MEDIO PROBATORIOS

5.1. Mediante Resolución N°08 con fecha 16 de agosto de 2023, se establecieron las cuestiones controvertidas

> ***"Primera cuestión controvertida referida a la Primera Pretensión Principal:*** *Que, el Tribunal Arbitral Unipersonal determine si corresponde o no declarar la nulidad, invalidez e ineficacia de la Resolución de Gerencia N°006-2023-MDT/GM, por medio de la cual la ENTIDAD resolvió el Contrato N°090-2022-MDT/GM.*
>
> ***Segunda cuestión controvertida referida a la Segunda Pretensión Principal:*** *Que, el Tribunal Arbitral Unipersonal determine si corresponde o no declarar que el avance parcial, establecido en el calendario de avance de obra vigente, es mayor al 80% del monto de la valorización acumulada programada a enero de 2023.*
>
> ***Tercera cuestión controvertida referida a la Pretensión Subordinada a la Segunda Pretensión Principal:*** *Si se determina que el avance parcial establecido en el calendario de avance de obra vigente es menor al 80% del monto de la valorización acumulada programada a enero de 2023, que el Tribunal Arbitral Unipersonal establezca si corresponde o no declarar si dicho retraso se encuentra justificado en acontecimientos o hechos no atribuibles a la empresa y, en base a ellos establecer si la ENTIDAD se encontraba o no habilitada para resolver el contrato N°090-2022-MDT/GM.*
>
> ***Cuarta cuestión controvertida referida a la Tercera Pretensión Principal:*** *Que, el Tribunal Arbitral Unipersonal determine si corresponde o no establecer si la obra, se encontraba paralizada del 01 al 24 de febrero de 2023, fecha en la que se notificó la Resolución de Gerencia N°006-2023-MDT/GM, por medio de la cual la ENTIDAD resolvió el Contrato N°090-2022-MDT/GM, por causas no atribuibles a la empresa; en consecuencia, suspendido para todos sus efectos el*

plazo de ejecución de obra en el período comprendido entre el 01 al 24 de febrero de 2023.

Quinta cuestión controvertida referida a la Cuarta Pretensión Principal: *Que, el Tribunal Arbitral Unipersonal determine si corresponde o no declarar la inaplicabilidad de otras penalidades dispuesta por la Entidad por el monto de S/ 214,068.20 (doscientos catorce mil sesenta y ocho con 20/100 soles) y, en el caso de que la ENTIDAD hubiera procedido a aplicar dicha penalidad, determinar si corresponde o no ordenar a la Municipalidad Distrital De Totos el reembolso a la empresa el monto de SI 214,068.20 (doscientos catorce mil sesenta y ocho con 20/100 soles."*

5.2. Mediante la citada Resolución N°08 de fecha de 16 de agosto de 2023 y en conformidad con el Art.40 del Reglamento se admitieron medios probatorios presentados por el CONTRATISTA en su escrito de Demanda Arbitral de fecha 10 de julio de 2023, señalados desde el literal a) hasta el literal s), y los medios probatorios presentados por la ENTIDAD en su escrito de Contestación a la Demanda Arbitral de fecha 02 de agosto de 2023, señalados en el numeral V del escrito.

VI. OTRAS ACTUACIONES ARBITRALES

6.1. Mediante Escrito de fecha 03 de noviembre de 2023, el Contratista presentó sus conclusiones, que derivan de la Audiencia de Informes Orales celebrada el 25 de octubre de 2023, en los siguientes términos:

6.1.1. Sobre la primera pretensión principal, se afirma haber acreditado que la resolución contractual realizada por el demandado no cumplió con los requisitos de fondo en cuanto la causal invocada dispuesta en el artículo 203.5 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, de modo tal que no resultan aplicables las causales por las que se resolvió el contrato, teniendo en cuenta que no existió un segundo retraso del Contratista en la ejecución de la obra bajo el cronograma actualizado por la Resolución de Alcaldía 112-2022.

6.1.2. Refiere que, tras un análisis lógico jurídico de las Resoluciones de alcaldía aprobadas por la Entidad, se puede corroborar que, al aprobarse el nuevo calendario, el anterior calendario acelerado en la Resolución de Alcaldía N°103-2022-MDT/A dejo de ser aplicable,

6.1.3. Asimismo, tras la audiencia actuada por el Árbitro Único, habrían advertido que en la Resolución de Gerencia N°006-2023 MDT/G, en la que se resolvió el Contrato, se evidencia que el porcentaje de avance es menor al programado acumulado a enero. Sin perjuicio de ello, la Entidad habría realizado el cálculo de avance acumulado de obra tomando en cuenta la ejecución del adicional, lo cual es invalido bajo la OPINIÓN OSCE No 043-2022/DTN-fundamento 2.1.2.2, en cuanto establece lo siguiente:

> *"(...) el artículo 203 del Reglamento indica que las demoras injustificadas en la ejecución de la obra pueden advertirse a partir del monto de la valorización acumulada ejecutada a una fecha determinada, así, cuando la ejecución es*

menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la valorización acumulada programada a dicha fecha, el inspector o supervisor ordenará al contratista la presentación de un nuevo calendario que contemple la aceleración de los trabajos de modo que se garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto (...)las prestaciones adicionales de obra aprobadas son pagadas mediante valorizaciones adicionales, por lo que dichas valorizaciones no se encuentran incluidas en las valorizaciones a las que se refiere el artículo 203 del Reglamento".

6.1.4. Sobre la segunda pretensión principal, se afirma que, mediante CARTA N°09-2023/HCIA SRL/SRT-TOTOS y CARTA N° 10-2023/HCIA SRL/SRT-TOTOS, se acreditó que el avance mensual de obra acumulado superó el 80% de lo programado en el Calendario de obra vigente establecido en la Res. Alcaldía N° 112-2022-MDT/A. Puesto que frente a lo programado en el avance de obra de 18.91% y el avance de obra acumulado programado de 69.04%; la empresa logró ejecutar un 13.96% de avance de obra mensual y, un 55.93% de avance de obra acumulado, siendo esto último el 81.01% de lo programado.

6.1.5. En cuanto a la primera pretensión subordinada a la segunda pretensión principal, refiere que se trate la misma solo si el árbitro determina que el avance de obra ejecutado hasta enero de 2023 es menor al 80% de lo programado en la Res. De Alcaldía N°112-2022-MDT/A. Por ende, señala haber acreditado que en las anotaciones en el cuaderno de obra, acta de constatación e inventario a 01 de marzo de 2023 y el acta de acuerdo suscrito entre las comunidades el día 03 de febrero, las intensas y constantes lluvias que saturan el terreno y perjudicó la utilización de concreto, arriesgando a los trabajadores, lo que configuraría una JUSTIFICACIÓN al ser hechos no atribuibles al Contratista y, por ende, la no aplicación del Art. 203.1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

6.1.6. Sobre la tercera pretensión principal, el demandante afirma que acreditó que la obra estuvo paralizada del 01 al 24 de febrero del 2023 como bien se indica en el cuaderno de obra- Asiento N°255, el Acta de acuerdo de suspensión de fecha 01/02/2023 y el Acta de acuerdo entre autoridades de fecha 03/02/2023, así como en la propia audiencia se habría advertido la inconsistencia en los medios probatorios presentado por la Entidad.

6.1.7. Sobre la cuarta pretensión principal, el demandante afirma que la Entidad transgredió el artículo 163 del RLCE que establece los criterios de objetividad, razonabilidad, congruencia y proporcionalidad en la aplicación de otras penalidades, debido a que en la cláusula "*Décima Tercera*" del Contrato, se refiere al procedimiento para el cálculo y cobro de otras penalidades, más no establece el procedimiento que permita a la Empresa realizar un descargo para que la Entidad verifique la configuración del supuesto de aplicación de penalidades. Por ende, considera que no existe documento que pruebe que la Entidad puso a conocimiento a la empresa sobre el cometimiento de los supuestos de aplicación de penalidades.

CONCLUSIONES DE LA ENTIDAD TRAS AUDIENCIA DE INFORMES ORALES

6.1.8. Sobre la primera pretensión principal, recalca que se comunicó el primer apercibimiento sobre el retraso injustificado de la empresa el 15 de septiembre

de 2022, con lo que se emitió la resolución de alcaldía N°112 – 2022- MDT/A de aprobación del nuevo calendario acelerado; y por tanto, afirman que se aplica el Art. 203.4 sobre "El nuevo calendario no exime al contratista de la responsabilidad por demoras injustificadas".

6.1.9. Sostiene que el nuevo calendario mediante programación PERT-CPM Y PROGRAMACIÓN GANTT, se estableció un plazo de ejecución concordante con el plazo acordado por la entidad de 240 días calendarios de inicio el 16 de agosto de 2023 y culminación el 12 de abril de 2022, no requiriendo ampliación de plazo.

6.1.10. Alega que el Contratista incurrió en un segundo retraso injustificado mediante el monto de la valorización acumulada siendo el monto de la valorización acumulada ejecutada menor a 80% que ameritó la resolución del contrato cumpliendo con todas las formalidades, conforme lo establece la Ley y el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, siendo que la Resolución Gerencial N° 006-2023-MDT/GM que resolvió el contrato, fue comunicada a la Empresa.

6.1.11. Respecto a la segunda pretensión principal, sobre que el avance parcial establecido en el calendario de obra vigente no es mayor al 80% a enero de 2023, debido a que la Empresa contratista en todas las valorizaciones, de agosto de 2022, octubre 2022, noviembre 2022, diciembre 2022 y enero 2023, ha venido retrasándose. Por ello, la Contratista habría emitido dos facturas diferentes, la primera por S/ 598, 562. 56 en la que adujeron superar el 80% con la valorización N°06, mientras que por la misma valorización adujeron una suma de 310,154.35, correspondiente a enero de 2023, siendo que de ahí se habría aceptado no haber superado el 80% del monto programado

6.1.12. Respecto a la primera pretensión subordinada a la segunda pretensión principal, se afirma que el Contratista aceptó no haber superado el 80%; mientras que, sobre los acontecimientos no atribuibles a su parte, alegados por el demandante. Siendo así, la Entidad se remite al artículo 203.4 del Reglamente de la Ley de Contrataciones del Estado, para señalar que la demora injustificada es responsabilidad de la empresa contratista.

6.1.13. Respecto a la Tercera pretensión principal, contrario a lo señalado por el demandante sobre la paralización de la obra del 01 al 24 de febrero del 2023, el demandado adjunta el informe de avance de obra de la valorización N°07 que evidencia un avance 4.51%; de igual manera se refieren a las fotos adjuntadas en la demanda, así como el pago de honorarios a trabajadores por los meses de enero y febrero.

6.1.14. El demandado recalcó la necesidad de seguir con el procedimiento formal de suspensión de obra, como se establece en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en tanto implica los diferentes pasos para la conformidad de la Entidad en cuanto a emitir una Resolución de Suspensión de Obra. Así, sostiene que el Contratista se limitó a presentar una solicitud de suspensión de obra sin justificación técnica, por lo cual alega que la Entidad no negó la solicitud, sino que realizó observaciones.

6.1.15. Así, se reitera que el Contratista tuvo conocimiento del proceso formal de suspensión, pero aun así decidió suspender unilateralmente mediante el asiento N°255 del cuaderno de obra, así como hicieron referencia a un Acta de acuerdo de la SEQUIA Piedra Blanca, en la que no hubo participación de técnica ni de la entidad ni del contratista, de la cual la Entidad señala que se omitió el Debido Proceso al ser un documento que no tiene validez para la formalidad del caso, más aún cuando la referida acta se acordó la paralización desde el 03 de febrero hasta el 20 de marzo, lo que contradice el plazo inicial precisado en el asiento N°255.

6.1.16. Sobre la cuarta pretensión, alegan que la Entidad ratificó la aplicación de la penalidad mediante el informe N°021-2023-MDT y el Informe N°034-2023-MDT/ de fecha 06 de junio del 2023 emitidos por la misma Municipalidad; así como mediante una opinión legal emitida por el Asesor Legal Externo de la Municipalidad.

6.1.17. Precisan que las penalidades aplicadas fueron de la valorización N°1 a la N°06, por la falta de EPP (S/2,468.20) y la ausencia de personal profesional (S/. 211,600.00; las cuales fueron aplicadas en amparo del art. 161.4 del RCLE.

6.1.18. Sobre la transgresión al debido procedimiento, la entidad concluye que sí comunicó la aplicación de penalidades mediante la Carta N°053-2023-MDT/RTM por lo que no se afectó el derecho a la defensa.

Otras actuaciones arbitrales

6.2. Mediante Resolución N°1 con fecha 30 de mayo 2023 se declaró instalado el Tribunal Arbitral dando inicio al procedimiento arbitral, y se otorgó a las partes (05) días hábiles contados tras notificada la siguiente resolución a fin de que se pronuncien sobre alguna modificación u observación

6.3. Mediante Resolución N°02 con fecha 08 de junio de 2023 se tuvo por presentado el escrito de Municipalidad Distrital de Totos, y se corrió traslado a HYDROCONSULTING INGENIEROS ASOCIADOS S.R.L a efectos de que en el plazo de cinco (05) días hábiles cumpla con pronunciarse en los términos que considere pertinente.

6.4. Mediante Resolución N°03 con fecha 22 de junio, se tuvo por apersonado a funciones designados por el señor alcalde de la Municipalidad Distrital de Totos, Wilson Retamozo Gálvez, a fin de que asuman el defensa técnico legal en representación de la Entidad; así mismo se aplicó las liquidaciones separadas en el presente proceso. Así mismo, mediante Resolución N°04 con fecha 06 de julio de 2023, se tuvo por presentado el escrito del contratista y se puso a conocimiento de la contratante.

6.5. Mediante Resolución N°05 con fecha de 14 de julio de 2023 se admitió la demanda arbitral presentada por HYDROCONSULTING INGENIEROS ASOCIADOS S.R.L. junto a sus medios probatorios anexados, así como los dos *otrosí digo* del Escrito de fecha 10 de julio de 2023 presentado por el

Contratista; y se otorgó a la Entidad, un plazo de (10) días hábiles contados a partir de notificada la resolución, a fin que conteste la demanda.

6.6. Mediante Resolución N°06 con fecha 31 de julio de 2023, se tuvo por presentados los escritos con fecha 20 de julio de 2023 y 24 de julio de 2023 de HYDROCONSULTING INGENIEROS ASOCIADOS S.R.L. y se puso a conocimiento de la parte contraria.

6.7. Mediante Resolución N°07 con fecha 08 de agosto de 2023 se tuvo por presentada la carta N°079-2023-MDT/RTM de la Entidad y se admitió a trámite la contestación arbitral presentada por la Entidad y sus medios probatorios adjuntos; así como el primer y segundo otrosí digo del escrito de fecha 02 de agosto de 2023 presentado la Entidad.

6.8. Mediante Resolución N°08 con fecha 16 de agosto de 2023 se fijó las cuestiones controvertidas y se admitieron los medios probatorios adjuntados en la demanda arbitral presentada por la Empresa y la Contestación de demanda presentada por la Entidad; y se otorgó a ambas partes el plazo de (05) días bailes a fin de que las partes se manifiesten conforme a derecho.

6.9. Mediante Resolución N°09 con fecha 31 de agosto de 2023, se tuvo por presentado el escrito de fecha 23 de agosto de 2023 de la Municipalidad Distrital de Totos, y se citó a las partes a Audiencia de Ilustración de Hechos para el día **viernes 15 de septiembre a las 9:00 a.m.**

6.10. Mediante Resolución N°10 con fecha 13 de septiembre de 2023 se volvió a señalar la participación de los profesionales en la audiencia programada para el 15 de septiembre de 2023. Así mismo mediante Resolución N°11 de fecha 15 de septiembre de 2023, se accedió a la solicitud formulada por la empresa HYDROCONSULTING INGENIEROS ASOCIADOS S.R.L. en su escrito de fecha 14 de septiembre de 2023. para ampliación de plazo de 05 días hábiles a fin que cumpla con el pago de honorarios arbitrales.

6.11. Mediante Resolución N°12 con fecha 26 de septiembre de 2023, se tuvo por cumplido con el pago de honorarios liquidados a través de la resolución N°09; y se declaró cerrada la etapa probatoria del presente proceso arbitral mediante lo cual se otorgó a las partes el plazo de (05) días hábiles a fin de que presenten sus alegatos finales.

6.12. Mediante Resolución N°13 con fecha 05 de octubre de 2023, se tuvo por presentado el escrito presentado por HYDROCONSULTING INGENIEROS ASOCIADOS S.R.L. con fecha 04 de octubre de 2023.y se puso a conocimiento de la Entidad; del mismo modo se tuvo por presentado el escrito de la Municipalidad Distrital de Totos con fecha 04 de octubre de 2023 y se puso a conocimiento de la Empresa. Por último, se citó a las partes para la Audiencia de Informes Orales a celebrar el 19 de octubre de 2023 a las 04:00 p.m.

6.13. Mediante Resolución N°14 con fecha 16 de octubre de 2023, se volvió a señalar la participación profesional Méndez, Porfirio Jauregui Torres, Dwayne Junior Quispe Torres y Teodoro López Tudelano en la audiencia programada.

Además, mediante Resolución N°15 se volvió a señalar la participación de Julio Hernán Salazar Morales y el señor Mario Ochoa Janampa en la audiencia de informes orales; y se reprogramó la audiencia de informes orales para el 25 de octubre de 2023 a las 04:00 p.m.

6.14. Mediante Resolución N°16 con fecha 06 de noviembre de 2015, se tuvo presente los escritos de fecha 03 de noviembre de 2023 presentado por la Entidad y por la Empresa; además se declaró cerrada las actuaciones arbitrales y se otorgó el plazo de (30) días hábiles para emisión del laudo arbitral, plazo que se extendía hasta el 20 de diciembre de 2023 inclusive. Mediante Resolución N°17 del 18 de diciembre de 2023, se extendió el plazo por quince (15) días hábiles adicionales.

6.15. En la fecha, dentro del plazo establecido, se emite el presente Laudo Arbitral.

CONSIDERANDO:

VII. CUESTIONES PREVIAS:

7.1. El expediente se encuentra en estado de laudar y dentro del plazo para ello, de conformidad con lo previsto en el acta de instalación y demás actuados en el presente caso arbitral, incluidas las pericias ordenadas, conforme se detalla en los acápites siguientes.

7.2. En forma previa al análisis de las materias controvertidas, corresponde confirmar lo siguiente:

i) En ningún momento se ha impugnado o reclamado contra las disposiciones del procedimiento dispuestas en las Reglas del Proceso, ni contra la competencia del árbitro único;
ii) Las partes no han formulado ningún tipo de objeción al arbitraje, han tenido plena oportunidad para ofrecer y actuar las pruebas que han considerado pertinente presentar, y han tenido la facultad de informar oralmente;
iii) Las partes tuvieron plena oportunidad para ofrecer y actuar todos sus medios probatorios.
iv) El análisis del presente caso y las conclusiones a las que arribe el Tribunal Arbitral Unipersonal, serán efectuadas de conformidad con la documentación aportada por las partes, así como de la información que de modo indubitable se desprende de los actuados que obran en el expediente del caso, habiéndose tenido en cuenta en su integridad, aún en caso de no ser expresamente mencionada en el análisis;
v) Los hechos a los que se refiere el análisis del caso son los establecidos en los antecedentes, en concordancia con la información que obra en el expediente del proceso, así como los que se mencionan en los demás acápites del presente Laudo Arbitral;

vi) El Tribunal Arbitral Unipersonal, conforme lo establecido en el artículo 139 numeral 1 de la Constitución Política del Perú, ejerce función jurisdiccional y, por lo tanto, no se encuentra subordinado a ningún órgano administrativo o de cualquier otra índole, ejerciendo sus funciones con absoluta independencia, en el marco de las competencias que son propias a su naturaleza;

vii) En el análisis de las pretensiones, el Tribunal Arbitral Unipersonal se ha reservado el derecho de seguir el orden que estima más conveniente para la solución de las controversias contenidas en los puntos controvertidos del presente caso arbitral;

viii) El Tribunal Arbitral Unipersonal, está procediendo a emitir el laudo dentro del plazo que corresponde a las reglas de este proceso.

VIII. NORMA APLICABLE

8.1. Acorde con la fecha de convocatoria del procedimiento de selección del cual deriva el Contrato objeto de análisis en el presente caso arbitral, la norma aplicable es el Texto Único Ordenado de Contrataciones del Estado de la Ley N° 30225, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF (En adelante la Ley o el TUO de la LCE). Del mismo modo, resulta aplicable el Decreto Supremo N°344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (en adelante, el Reglamento, o RLCE) y sus normas modificatorias.

Ambos cuerpos normativos son las aplicables para todos los contratos suscritos como consecuencia de los procedimientos de selección convocados entre el 30 de enero de 2019 a la fecha.

8.2. Asimismo, resulta aplicable al presente caso el Decreto Legislativo N°1071, Ley que Norma el Arbitraje, así como las disposiciones establecidas en el Reglamento de Arbitraje del Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas – CECARD, así como los principios, usos y costumbres en materia arbitral y contractual.

IX. ANÁLISIS

9.1. De conformidad con los términos establecidos en la fijación de puntos controvertidos, en el presente caso tenemos un total de cinco pretensiones pendientes de resolver, de las cuales cuatro de ellas se encuentran referidas a la decisión de la Entidad de resolver el Contrato y, la quinta, a determinar la pertinencia o no de la aplicación de otras penalidades.

Asimismo, de las cuatro pretensiones referidas a la resolución del Contrato o a las condiciones que dieron origen a tal decisión, una de ellas se refiere a la decisión propiamente dicha, dos al estado de avance superior o inferior al 80% de lo programado y, la última de este grupo, a determinar si la obra se encontraba paralizado o no – por causas no atribuibles al Contratista – a la fecha de resolución del Contrato.

9.2. Para efectos metodológicos dividiremos nuestro análisis en: i) Las pretensiones relativas a la resolución del Contrato y; ii) pretensión relativa a la decisión de aplicar o no las "Otras penalidades" impuestas por la Entidad.

Todo lo anterior sin perjuicio de determinar la asignación de los costos y costas procesales.

Pretensiones relativas a la resolución del Contrato

9.3. En este apartado tenemos un total de cuatro pretensiones, vinculadas a la pertinencia o no de la decisión de la Entidad de resolver el Contrato, tanto las referidas al sustento utilizado para ello, a la oportunidad en la que se llevó a cabo y, finalmente, al acto resolutorio propiamente dicho, conforme a lo siguiente:

> ***"Primera cuestión controvertida referida a la Primera Pretensión Principal:*** *Que, el Tribunal Arbitral Unipersonal determine si corresponde o no declarar la nulidad, invalidez e ineficacia de la Resolución de Gerencia N°006-2023-MDT/GM, por medio de la cual la ENTIDAD resolvió el Contrato N°090-2022-MDT/GM.*
>
> ***Segunda cuestión controvertida referida a la Segunda Pretensión Principal:*** *Que, el Tribunal Arbitral Unipersonal determine si corresponde o no declarar que el avance parcial, establecido en el calendario de avance de obra vigente, es mayor al 80% del monto de la valorización acumulada programada a enero de 2023.*
>
> ***Tercera cuestión controvertida referida a la Pretensión Subordinada a la Segunda Pretensión Principal:*** *Si se determina que el avance parcial establecido en el calendario de avance de obra vigente es menor al 80% del monto de la valorización acumulada programada a enero de 2023, que el Tribunal Arbitral Unipersonal establezca si corresponde o no declarar si dicho retraso se encuentra justificado en acontecimientos o hechos no atribuibles a la empresa y, en base a ellos establecer si la ENTIDAD se encontraba o no habilitada para resolver el contrato N°090-2022-MDT/GM.*
>
> ***Cuarta cuestión controvertida referida a la Tercera Pretensión Principal:*** *Que, el Tribunal Arbitral Unipersonal determine si corresponde o no establecer si la obra, se encontraba paralizada del 01 al 24 de febrero de 2023, fecha en la que se notificó la Resolución de Gerencia N°006-2023-MDT/GM, por medio de la cual la ENTIDAD resolvió el Contrato N°090-2022-MDT/GM, por causas no atribuibles a la empresa; en consecuencia, suspendido para todos sus efectos el plazo de ejecución de obra en el período comprendido entre el 01 al 24 de febrero de 2023.*

9.4. Para los efectos, cabe recordar que el Contrato materia del presente análisis fue suscrito el 19 de julio de 2022, con un plazo de ejecución de 240 días calendario, los cuales – teniendo en cuenta la fecha de inicio del plazo de

obra (16 de agosto de 2022), culminaban el 12 de abril de 2023. De la información que obra en autos, no se aprecia que durante su vigencia se haya aprobado ampliación de plazo alguna, pero si el denominado Deductivo - Adicional de Obra N°01.

9.5. En tal sentido, para analizar debidamente las tres pretensiones principales y la pretensión subordinada incluidas en el presente rubro, es necesario tener en claro diversos aspectos, tales como el calendario de obra vigente, el calendario de obra acelerado, así como la razonabilidad de las disposiciones establecidas en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado respecto de los márgenes de atrasos en obra permisibles, como las consecuencias que se derivan de un ritmo de avance menor a sus límites inferiores.

9.6. Al respecto, debe diferenciarse entre lo que viene a ser el plazo de ejecución de obra, respecto del ritmo de avance de ésta. La primera de estas figuras se constituye como un límite final, máximo, dentro del cual la obra debe estar apta para su recepción, de modo tal que, de superarse tal tope calendario máximo, se inicie el cómputo de la penalidad por mora, en las condiciones y consecuencias establecidas en el artículo 162° del citado Reglamento.

La segunda de las figuras mencionadas, es decir el ritmo de avance de obra, implica que durante la ejecución de ésta debe seguirse una progresión que permita su adecuada culminación dentro de los plazos máximos establecidos. Ello en el entendido que una obra constituye un conjunto de pasos secuencias, que implican un desarrollo sostenido y sostenible, en el marco de un calendario de ejecución realizable.

9.7. En esa línea, el Legislador advierte que, de no seguirse un adecuado ritmo de avance, la obra no podrá culminarse dentro de su plazo máximo, de ahí que establezca ritmos de atraso tolerables, así como los remedios necesarios en caso de que el desfase en su avance se encuentre por encima de dicho límite máximo de atraso. Como veremos a continuación, dicho límite máximo tolerable es del 20%, de modo tal que se han previsto remedios específicos cuando el ritmo de avance no alcanza el 80% de lo programado.

9.8. En efecto, el primer y segundo párrafos del artículo 203° del Reglamento, establecen lo siguiente:

> *"203.1. Durante la ejecución de la obra, el contratista está obligado a cumplir los avances parciales establecidos en el calendario de avance de obra vigente. En caso de retraso injustificado, <u>cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada a una fecha determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la valorización acumulada programada a dicha fecha, el inspector o supervisor ordena al contratista que presente, dentro de los siete (7) días siguientes, un nuevo calendario que contemple la aceleración de los trabajos</u>, de modo que se garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto, anotando tal hecho en el cuaderno de obra.*

203.2. El calendario acelerado es revisado por el supervisor o inspector de obra, quién a su vez en un plazo de tres (3) días otorga conformidad y lo eleva a la Entidad para su aprobación en un plazo de siete (7) días, contados a partir del día siguiente de la recepción del informe del inspector o supervisor. De no pronunciarse la Entidad en el plazo señalado, se tiene por aprobado el calendario elevado por el inspector o supervisor."

(El subrayado es nuestro)

9.9. Nótese, en este sentido, que los párrafos citados distinguen claramente entre un denominado "***Calendario de obra vigente***" respecto de un "***Calendario acelerado***". Como queda claro de los tercer y cuarto párrafos del citado artículo 203, el calendario acelerado no sustituye al calendario vigente sino únicamente para el control de los avances físicos reprogramados, es decir sólo para medir el avance de la obra (y determinar si sigue por debajo o está por encima del nuevo 80%), sin que genere ningún otro efecto contractual:

"203.3. <u>Dicho calendario se toma en cuenta solo con fines del control de los avances físicos reprogramados de la obra</u> y no para el análisis de afectación de la ruta crítica con fines de trámite de ampliaciones de plazo, para cuyo caso se considera el último calendario actualizado vigente.

203.4. La falta de presentación de este calendario dentro del plazo señalado en el numeral precedente puede ser causal para que opere la intervención económica de la obra o la resolución del contrato. El nuevo calendario no exime al contratista de la responsabilidad por demoras injustificadas, ni es aplicable para el cálculo y control de reajustes ni para sustentar las solicitudes de ampliaciones de plazo."

(El subrayado es nuestro)

9.10. Es decir, si se trata de determinar si la obra está cumpliendo con un grado de avance igual o mayor al 80% de lo programado, se tendrá en cuenta el calendario acelerado; pero si - por el contrario - de lo que se trata es determinar si procede una ampliación de plazo o el cálculo de pago de reajustes, se seguirá teniendo en cuenta el denominado calendario vigente.

La lógica es simple: De lo que se trata es de superar el atraso existente, sin que ello genere un beneficio económico adicional al Contratista.

9.11. Así las cosas, tal figura – la del calendario acelerado – tiene como objetivo evitar una resolución de contrato y reestablecer el ritmo de avance a un nivel que permita la culminación oportuna de los trabajos contratados, favoreciendo con ello el cumplimiento de la finalidad pública (vía la culminación de la obra).

9.12. El incumplimiento de tal calendario acelerado trae consigo sus propias consecuencias, como bien lo establece el quinto y último párrafo del tantas veces citado artículo 203° del Reglamento:

> *"203.5. Cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada es menor al ochenta por ciento (80%) del monto acumulado programado del nuevo calendario[1], el inspector o el supervisor anota el hecho en el cuaderno de obra e informa a la Entidad. Dicho retraso puede ser considerado como causal de resolución del contrato o de intervención económica de la obra, no siendo necesario apercibimiento alguno al contratista de obra."*

Ello quiere decir que, si se aprueba un calendario acelerado – que siempre se establece en función a un calendario vigente - como ya se ha explicado y, este calendario acelerado no se cumple, la respectiva entidad tiene dos opciones: i) O bien intervenir económicamente la obra; ii) O bien resolver el contrato, sin necesidad de un requerimiento previo.

9.13. Ahora bien ¿Y qué ocurre si durante la ejecución de un contrato se aprueba un nuevo ***Calendario de obra vigente***?: Entendamos para ello, la secuencia a la cual nos referimos:

- Existe un primer calendario de obra vigente.
- Luego, se aprueba un calendario acelerado al no alcanzarse un avance igual o superior al 80% de ese calendario de obra vigente, sin que este último pierda vigencia (salvo para el control de los avances físicos programados).
- Posteriormente, se aprueba un nuevo calendario de obra vigente. ¿Qué ocurre entonces con el calendario acelerado del calendario de obra previo, es decir del que ha quedado sin efecto por aprobación del posterior?

9.14. Debe tenerse en cuenta que todo calendario acelerado se aprueba en función de un calendario de obra vigente, en una evidente relación de accesoriedad del primero respecto del segundo.

De este modo, si el calendario de obra vigente pierde efecto al ser sustituido por otro, su calendario accesorio, es decir el acelerado, pierde igualmente vigencia.

9.15. Respecto del caso que nos ocupa, tenemos que, ante el atraso acaecido respecto del calendario de obra original, mediante la Resolución de Alcaldía N°112-2022-MDT/A del 27 de setiembre de 2022, se aprobó su calendario acelerado, manteniendo como fecha de culminación del plazo contractual, el día 12 de abril de 2023.

9.16. Sin embargo, ante la aprobación del Deductivo – Adicional de Obra N°1 y Deductivo – Adicional de Obra N°01, la Entidad con fecha 26 de octubre de 2022 mediante Resolución N°112-2022-MDT/A, de modo expreso dispuso en su primer punto resolutivo, lo siguiente:

---

[1] Es decir, del calendario acelerado.

"***ARTÍCULO PRIMERO***. – *APROBAR, el Calendario de Obra Actualizado por Deductivo – Adicional de Obra N°01 y Deductivo – Adicional Vinculante de Obra N°01, de la Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PIEDRA BLANCA - WICHINKA EN EL CENTRO POBLADO DE CHACABAMBA, DISTRITO DE TOTOS -CANGALLO – AYACUCHO", con CODIGO UNIFICADO N°23179199 con el siguiente detalle: (…)"*

9.17. Este nuevo calendario, no es uno acelerado, sino que modifica al calendario de obra original del Contrato y lo sustituye, máxime si como se evidencia de su propio texto y del contenido de la resolución que lo contiene, se varían las partidas a ejecutar y las que ya no serán ejecutadas.

El hecho que tales deductivos y adicionales no modifiquen el plazo último de culminación de la obra (12 de abril) no es óbice para tener en cuenta que establece un nuevo orden y estructura respecto de los trabajos que deben realizarse, siendo las nuevas reglas para tenerse en cuenta para la ejecución del resto del Contrato.

9.18. De este modo, al 23 de febrero de 2023, que fue la fecha de resolución del Contrato dispuesta por la Entidad, tenemos el siguiente cuadro – que tiene en cuenta los calendarios de obra y el calendario acelerado aprobados durante su ejecución, conforme a lo siguiente:

	Tiene calendario acelerado	**Se encuentra vigente (al 24.02.2023)**
Calendario de obra original	SI	NO
Calendario de obra aprobado por la Resolución 112-2022-MDT/A	NO	SI

9.19. La Entidad sostiene que, al haberse aprobado el ***Calendario de Obra Acelerado***, no correspondía aprobar ampliación de plazo alguno, como tampoco mayores montos por reajustes, agregando que el nuevo calendario (es decir el acelerado) no exime al contratista de la responsabilidad por demoras injustificadas, todo lo cual resulta estrictamente cierto. Sin embargo, de ello no se puede colegir que, ante la aprobación de deductivos y adicionales – que evidentemente no corresponden a hechos imputables al Contratista, se le puede oponer un calendario previo que ha quedado desfasado.

En esa línea, el calendario acelerado aprobado el 27 de septiembre de 2022 como accesorio al calendario de obra original, quedó sin efecto cuando este último ha quedado sustituido por el aprobado el 26 de octubre de 2022, que era el único vigente en la oportunidad en la cual la Entidad decidió resolver el Contrato.

9.20. Siendo el calendario aprobado el 26 de octubre de 2022 el único vigente a la fecha de resolución del Contrato (23 de febrero de 2023), el Contratista ha

reconocido que igualmente se encontraba atrasado respecto de su ejecución, pero precisando que dicho menor ritmo no implicaba un avance menor al 80%, señalando expresamente que se había alcanzado el 81.01%.

Para tales efectos, refiere que el mes de enero de 2023 tenía programado un avance del 18.25%, pero solo alcanzó al 13.96%, con lo cual – según sus propios cálculos, alcanzaría un total acumulado del 81.01% respecto 69.04% meta, conforme a su Valorización N°6.

9.21. Sin embargo, la Supervisión efectúa un cálculo distinto, por el que considera que el avance de enero fue del 7.95%, y un retraso del 10.96 para dicho período de ejecución, situación que ubicaría al Contratista por debajo del 80%. Este porcentaje de avance es refrendado por la Entidad, en la propia documentación que ha emitido sobre el tema.

De la información que obra en autos, no se advierte que el Contratista haya refutado de modo expreso los cálculos efectuados por su parte, respecto de los realizados por la Supervisión, pese a tratarse de la parte demandante y, conforme a ello, la obligada a sustentar la posición que pretende validar como parte de sus pretensiones.

9.22. En tal sentido, queda claro que el Contratista al 31 de enero de 2023, se encontraba por debajo del 80% respecto del Calendario de Obra aprobado el 26 de octubre de 2022. Sin embargo, no puede considerarse que se trate de un segundo caso de atraso por debajo del 80% respecto de dicho calendario vigente ni, por ende, del incumplimiento del calendario acelerado previo, el cual tenía su sustento directo en un primer calendario de obra, que ya no se encontraba vigente.

9.23. Así las cosas, el atraso incurrido al 31 de enero de 2023 correspondía a un hecho nuevo, vinculado en este caso al calendario de obra aprobado el 26 de octubre de 2022, es decir a un primer evento en el cual este último sufría un desfase que lo ubicaba por debajo del límite inferior del 80%. En este caso, correspondía reiniciar previsto en los párrafos primero y segundo del artículo 203° del Reglamento y no así aplicar de modo directo lo establecido en el párrafo quinto.

9.24. En efecto, nótese que el mencionado párrafo quinto contempla lo siguiente, refiriéndose siempre al incumplimiento del calendario acelerado, pues es directa continuación de los cuatro párrafos anteriores, para lo cual citamos en esta ocasión el artículo 203° de modo completo:

> ***"Artículo 203. Demoras injustificadas en la ejecución de la Obra***
>
> *203.1. Durante la ejecución de la obra, el contratista está obligado a cumplir los avances parciales establecidos en el calendario de avance de obra vigente. En caso de retraso injustificado, cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada a una fecha determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la valorización acumulada programada a dicha fecha, el inspector o supervisor ordena al contratista que presente, dentro de los siete (7) días siguientes, <u>un nuevo calendario que contemple la aceleración</u>*

de los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto, anotando tal hecho en el cuaderno de obra.

203.2. El calendario acelerado es revisado por el supervisor o inspector de obra, quién a su vez en un plazo de tres (3) días otorga conformidad y lo eleva a la Entidad para su aprobación en un plazo de siete (7) días, contados a partir del día siguiente de la recepción del informe del inspector o supervisor. De no pronunciarse la Entidad en el plazo señalado, se tiene por aprobado el calendario elevado por el inspector o supervisor.

203.3. Dicho calendario se toma en cuenta solo con fines del control de los avances físicos reprogramados de la obra y no para el análisis de afectación de la ruta crítica con fines de trámite de ampliaciones de plazo, para cuyo caso se considera el último calendario actualizado vigente.

203.4. La falta de presentación de este calendario dentro del plazo señalado en el numeral precedente puede ser causal para que opere la intervención económica de la obra o la resolución del contrato. El nuevo calendario no exime al contratista de la responsabilidad por demoras injustificadas, ni es aplicable para el cálculo y control de reajustes ni para sustentar las solicitudes de ampliaciones de plazo.

203.5. Cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada es menor al ochenta por ciento (80%) del monto acumulado programado del nuevo calendario, el inspector o el supervisor anota el hecho en el cuaderno de obra e informa a la Entidad. Dicho retraso puede ser considerado como causal de resolución del contrato o de intervención económica de la obra, no siendo necesario apercibimiento alguno al contratista de obra."

(Los subrayados son nuestros)

9.25. Como puede advertirse del citado párrafo quinto, lo que faculta a la Entidad o bien a intervenir la obra o bien a resolver el Contrato sin necesidad de apercibimiento previo, es que se incumpla el ***calendario acelerado***, es decir que este no alcance (de modo injustificado) al menos el 80% de su programación.

Tal como hemos visto en el presente análisis, al 23 de febrero de 2023 no existía ***calendario acelerado*** alguno que se encontrase vigente, sino únicamente el ***calendario de obra aprobado el 26 de octubre de 2022***, motivo por el cual no se dio el supuesto resolutorio contemplado en el citado párrafo quinto.

9.26. Con todo lo expuesto, queda claro que la decisión resolutoria efectuada por la Entidad respecto al atraso acaecido respecto del nuevo calendario de obra devino en prematura y, por ende, debe quedar sin efecto.

9.27. Por otro lado, el Contratista – como parte de sus pretensiones, solicita de modo subordinado, que se declare que, en caso de existir atraso en el calendario de obra vigente superior al 20% de lo programado, se determine que dicho atraso era justificado. Dicha pretensión ha sido planteada en subordinación – no de la decisión resolutoria de la Entidad, sino respecto de la existencia del

propio atraso, por lo cual corresponde su análisis, habida cuenta que – entre las conclusiones de nuestro análisis - se tiene que, si bien la resolución del Contrato dispuesta por la Entidad no resulta válida, si se produjo un atraso superior al 20% del calendario de obra vigente, para el mes de enero de 2023.

9.28. Al respecto, el Contratista hace referencia a diversos eventos de lluvia acaecidos durante los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023, que habrían impedido un normal desarrollo de los trabajos programados. Para tales efectos, cita reiterados asientos de su residente de obra, así como asientos de la propia Supervisión, en los que se deja constancia de los problemas e interrupciones producidos por lluvias - en incluso granizo – por el mencionado período.

9.29. Sin embargo, no debe olvidarse que el calendario de obra vigente es el aprobado el 26 de octubre de 2022, en el que debía contemplarse la estacionalidad correspondiente al período de lluvias que va de diciembre a marzo inclusive. En esa línea, el Contratista no acredita con su demanda – de modo documentado – una excepcionalidad de dichas lluvias, sino simplemente su ocurrencia y los efectos que ellas producen en un período en el cual éstas son perfectamente previsibles.

Así, que en el cuaderno de obra se detalle los efectos de tales lluvias en días específicos, no implica por sí mismo que tales eventos se encuentren por encima de los estándares usuales, ni el por qué se establecieron al 19.85% y 18.91% respectivamente, por dos meses en los cuáles resultaba previsible la existencia de interrupciones propia de la estación climática indicada.

9.30. En consecuencia, el Árbitro Único considera que no se ha acreditado de modo fehaciente la situación de excepcionalidad de los eventos climáticos identificados por el Contratista y, por el mismo motivo, no existen elementos para concluir que el atraso acaecido respecto al segundo calendario de obra, devenga en justificado.

9.31. Finalmente, respecto a la tercera pretensión principal de la demanda, el Contratista plantea que el árbitro declare que la obra se encontraba paralizada, al 24 de febrero de 2023, cuando se le notificó la resolución contractual dispuesta por su contraparte fechada el día anterior y si, como consecuencia de ello, el plazo de ejecución se encontraba suspendido para todos sus efectos para tal oportunidad.

Puede inferirse, de lo planteado por el Contratista, que lo que pretende en estricto es que se emita un pronunciamiento que, por un sustento distinto a los ya analizados, se refiera a la imposibilidad de resolver un contrato cuando exista de por medio una paralización de su plazo de ejecución.

9.32. Si bien en el presente Laudo el árbitro se ha pronunciado ya sobre la invalidez de la resolución del Contrato dispuesta por la Entidad, al referirse a un fundamento distinto – que no ha sido planteado de modo subordinado, sino como pretensión principal, corresponderá igualmente proceder a su análisis.

9.33. Al respecto, el Contratista sostiene que mediante el asiento 255 del 1 de febrero de 2023, su residente anotó en el cuaderno de obra la suspensión de la ejecución de la obra, en razón a los eventos climáticos tales como lluvias y tormentas eléctricas, que pondrían en riesgo la seguridad y salud de sus trabajadores, así como la propia continuidad en la ejecución de los trabajos.

Asimismo, hace referencia al acta de acuerdos llevado a cabo el 3 de febrero de 2023 con la participación de diversos representantes y dirigentes de las comunidades beneficiarias de la obra en ejecución, así como del alcalde distrital de Totos, Dr. Wilson Retamozo Gálvez, por la cual se acordaría paralizar la obra entre el 03 de febrero y el 20 de marzo de 2023.

9.34. Por su parte, la Entidad niega la validez de la mencionada acta, al señalar que no ha seguido el procedimiento formal para la aprobación de una suspensión del plazo de obra, no ha contado con una aprobación válida y, más aún, quien firma por el Contratista no tendría representación ni facultades para suscribir documento alguno a su nombre.

Asimismo, sostiene que la obra no se ha paralizado y que, inclusive, el Contratista valorizó un avance del 4.51% para el mes de febrero de 2023 y que no existe consistencia respecto de lo alegado, puesto que se refiera a una paralización del 1 de febrero de 2023, pero el acta en el cual se sustenta el pedido se suscribió recién el día 3 de los mismos.

9.35. Se advierte sobre el tema bajo análisis, que el Contratista utiliza de modo indistinto los términos "paralización" y "suspensión" del Contrato, si bien en estricto se trata de situaciones distintas, puesto que la primera corresponde a una situación de facto, es decir a un hecho material que impide continuar con la ejecución de los trabajos contratados, mientras que la segunda corresponde a un acuerdo específico entre las partes, derivada de tal situación material.

9.36. Tal diferenciación se advierte con toda claridad en el primer párrafo del artículo 178° del Reglamento, el cual establece lo siguiente:

> ***"Artículo 178. Suspensión del plazo de ejecución***
>
> *178.1. Cuando se produzcan <u>eventos no atribuibles a las partes que originen la paralización de la obra</u>, <u>estas pueden acordar por escrito la suspensión del plazo de ejecución de la misma</u>, hasta la culminación de dicho evento, sin que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos, salvo aquellos que resulten necesarios para viabilizar la suspensión."*
>
> (El subrayado es nuestro)

9.37. De este modo, queda claro que no puede existir una suspensión unilateral, dado que esta debe ser necesariamente pactada. En este sentido, pese a que se encuentra planteada literalmente con esta última mención, el asiento 255 del residente de la obra, no constituye per se una suspensión del Contrato, sino únicamente su posición respecto de la potencial existencia de una causal de paralización de obra.

El mismo término "paralización" es el utilizado en el documento suscrito el 03 de febrero del mismo año. Por ende, a fin de uniformizar y según la línea de lo solicitado en la tercera pretensión principal, que expresamente se refiere al término "*paralización*", es sobre dicha figura de facto o material, que se llevará a cabo nuestro análisis.

9.38. La pregunta es simple: ¿Hubo paralización entre el 1 o el 3 de febrero hasta el 24 de febrero de 2023?; si la respuesta es positiva ¿Ello hubiera impedido a la Entidad a plantear la resolución del Contrato?

9.39. El primer elemento para descartar es la posibilidad de tener como válido al 1 de febrero como fecha de inicio de una potencial paralización. No se advierte diferencias entre lo acaecido en el mes previo, es decir en enero de 2023 y la situación acaecida al día siguiente, en tanto se aludía al mismo evento climático y a los obstáculos que generaban sobre los trabajos en desarrollo.

Así, lo que corresponde determinar es si puede darse por válida una paralización entre el 3 de febrero y el 24 de febrero de 2023 (sin que se extienda hasta el 20 de marzo de 2023 por efecto de la decisión resolutoria de la Entidad). Es necesario destacar que la respuesta nace de analizar un acuerdo que no define sus alcances como los de una "*suspensión*" sino únicamente como una "*paralización*", es decir, como una situación de facto.

9.40. De una simple lectura del acta mencionada, se advierte que esta contiene menciones diversas, incluidos aspectos laborales, menciones a la ejecución de la obra y a su estado, así como una mención muy somera a los problemas generados por las lluvias. En general, se advierte una participación anómica de los asistentes a la sesión.

9.41. Sin embargo, no puede sostenerse que solo se trata de un documento suscrito por los pobladores de la Comunidad de Chacabamba, sino como se puede leer del documento, participa de ella la Supervisión de Obra y el propio alcalde de la Municipalidad Distrital de Totos, como máxima autoridad ejecutiva edil.

La representación de dicha autoridad está fuera de duda, como se aprecia de la propia contestación a la demanda efectuada por la Entidad, que fue suscrita por el mencionado alcalde Dr. Wilson Retamozo Gálvez.

9.42. En todo caso, el documento del 3 de febrero de 2023 debe tenerse como una declaración o reconocimiento de hecho. Aún si quien participa por parte de la empresa carecía de la debida representación – afirmación de la Entidad

que no ha sido refutada por la parte demandante, no es menor cierto que existe al menos una declaración de parte – la estatal – que manifiesta su posición sobre la pertinencia de paralizar la obra.

9.43. Ahora bien, reiteramos que no puede confundirse la paralización de obra con la figura de la suspensión. Es sólo la segunda la que tiene un refrendo contractual propiamente dicho, mientras que la primera constituye únicamente una situación material.

9.44. Una obra paralizada puede dar lugar a un pacto de suspensión o, de no darse este, al menos a una situación que posteriormente pudiese dar motivo o bien a un pedido de ampliación de plazo o bien a uno de justificación de atraso. Sin embargo, la ocurrencia de tal hecho material, no implica *per se* la suspensión de las obligaciones contractuales de las partes.

9.45. Incluso si se hubiese pactado de modo expreso una suspensión del Contrato – lo que no se aprecia de la documentación aportada por las partes, ello implica únicamente que no corre el cómputo del plazo de tal Contrato, pero en ningún momento que se produzca una interrupción absoluta del conjunto de derechos y obligaciones que corresponden a la Entidad y al Contratista, de modo tal que no existe impedimento para resolver el vínculo del Contrato, por ejemplo, si a tenor de una de ellas, deviniese en imposible la continuación de los trabajos contratados.

Dicho de otro modo, ni la suspensión del plazo de ejecución del contrato de obra implica que no se genere efecto alguno entre las partes mientras esta se prolongue; ni la paralización de la obra implica por sí misma, la existencia de un acuerdo de suspensión.

9.46. Tratándose de una paralización, en el entendido de una situación material, su levantamiento puede darse igualmente de facto, es decir sin un nuevo acuerdo, basta para ello la actuación material que implique la reanudación de los trabajos contratados.

9.47. Así, puede advertirse que el Supervisor ha imputado al Contratista diversas ausencias en obra durante el mes de febrero de 2023 adjuntando para ello el panel fotográfico correspondiente a diversos días y horas del mencionado mes, las que han sido respondidas por el actual demandante, ya sea señalando que las visitas se hicieron en hora de almuerzo, en día no laborable o luego de la fecha de resolución del Contrato.

Es decir, no niega su actividad en obra, sino la oportunidad en la cual se efectuaron las respectivas visitas – a las que considera incluso maliciosas.

9.48. Del mismo modo, el Contratista no ha negado ni refutado por sostenido por su contraparte en cuanto a la existencia de una valorización por el 4.51% por el mes de febrero de 2023, situación que solo resulta posible en tanto se haya realizado trabajos en el mencionado período.

9.49. En tal sentido, debe desestimarse la tercera pretensión principal del Contratista.

9.50. Como consecuencia de todo lo expuesto, las cuatro pretensiones bajo análisis deben ser resueltas del siguiente modo:

> *"Declarar **FUNDADA** la Primera Pretensión Principal de la demanda y, por su efecto, determínese que corresponde declarar la nulidad invalidez e ineficacia de la Resolución de Gerencia N°006-2023-MDT/GM, por medio de la cual la ENTIDAD resolvió el Contrato N°090-2022-MDT/GM.*
>
> *Declarar **INFUNDADA** la Segunda Pretensión Principal de la demanda y, por su efecto, determínese que no corresponde declarar que el avance parcial establecido en el calendario de avance de obra vigente es mayor al 80% del monto de la valorización acumulada programada a enero de 2023.*
>
> *Declarar **INFUNDADA** la pretensión subordinada a la Segunda Pretensión Principal de la demanda y, por su efecto, determínese que no corresponde declarar que el avance menor al 80% del calendario de obra vigente, se encuentra justificado en acontecimientos o hechos no atribuibles a la empresa.*
>
> *Declarar **INFUNDADA** la Tercera Pretensión Principal de la demanda y, por su efecto, determínese que no corresponde declarar que la obra se encontraba paralizada y el contrato suspendido para todos sus efectos por el período comprendido entre el1 al 24 de febrero de 2023."*

9.51. Es importante tener en cuenta que, al declararse fundada la primera pretensión principal de la demanda, el Contrato retoma formalmente su vigencia. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el árbitro ha tomado conocimiento, a través de la solicitud cautelar planteada por el Contratista, por la cual acreditaba la existencia de diversos actos de la Entidad orientados -bajo su responsabilidad - a contratar el saldo de obra, situación que ha sido reconocida por la parte municipal.

En tal sentido, si a la fecha del presente Laudo Arbitral no resultase posible la continuación del Contrato materia del presente análisis, corresponderá a las partes adoptar las acciones pertinentes para la adecuada conclusión y cierre de este, teniendo en cuenta las consecuencias de lo resuelto en el presente documento.

Respecto de la pertinencia o no de aplicar las "Otras penalidades" impuestas por la Entidad

9.52. Este tema corresponde al quinto punto controvertido o cuarta pretensión de la demanda, que el Contratista ha planteado del siguiente modo:

Quinta cuestión controvertida referida a la Cuarta Pretensión Principal: *Que, el Tribunal Arbitral Unipersonal determine si corresponde o no declarar la inaplicabilidad de otras penalidades dispuesta por la Entidad por el monto de S/ 214,068.20 (doscientos catorce mil sesenta y ocho con 20/100 soles) y, en el caso de que la ENTIDAD hubiera procedido a aplicar dicha penalidad, determinar si corresponde o no ordenar a la Municipalidad Distrital De Totos el reembolso a la empresa el monto de SI 214,068.20 (doscientos catorce mil sesenta y ocho con 20/100 soles.*

9.53. Sobre el tema, cabe recordar que el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece la posibilidad de imponer al respectivo contratista diversas penalidades, orientadas a desalentar diversas conductas no deseadas por el Legislador. Tales conductas están referidas, por un lado, al cumplimiento del plazo pactado, en cuyo caso estamos frente a las penalidades por mora y; por el otro, a un conjunto heterogéneo de conductas – a las que se denomina en oposición como "Otras penalidades".

9.54. Sobre este tema, la Opinión N°023-2017/DTN de la Dirección Técnica Normativa del OSCE del 31 de julio de 2017, en su acápite 2.1., establece como la finalidad de tales "*Otras penalidades*", la siguiente:

> "De acuerdo con el artículo citado, la Entidad podía establecer, **en las Bases del proceso de selección**, penalidades distintas a penalidad por mora –*entiéndase, "otras penalidades"*– con la finalidad de desincentivar el incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista y resarcir posibles perjuicios que dicho incumplimiento le fuese a causar."

9.55. Así, el artículo 161° del Reglamento, en sus dos primeros párrafos, establece lo siguiente:

> ***"Artículo 161. Penalidades***
>
> *161.1. El contrato establece las penalidades aplicables al contratista ante el <u>incumplimiento injustificado</u> de sus obligaciones contractuales a partir de la información brindada por el área usuaria, las mismas que son objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria.*
>
> *161.2. La Entidad prevé en los documentos del procedimiento de selección <u>la aplicación de la penalidad por mora; asimismo, puede prever otras penalidades</u>. Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse."*

9.56. A primera línea, puede advertirse que uno de los requisitos que ameritan la aplicación de penalidades, es que exista un incumplimiento que sea imputable al respectivo contratista, es decir, que sea injustificado.

9.57. Por su parte, el artículo 163° del Reglamento, detalla las características que se deben cumplir para que corresponda aplicar las mencionadas "*Otras penalidades*", como se aprecia de su texto:

> ***"Artículo 163. Otras penalidades***
>
> *163.1. Los documentos del procedimiento de selección pueden establecer penalidades distintas a la mencionada en el artículo 162, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación. Para estos efectos, incluyen los supuestos de aplicación de penalidad, distintas al retraso o mora, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.*
>
> *163.2. Estas penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora."*

9.58. Como puede apreciarse, a diferencia de las penalidades con mora, que se aplican con la sola constatación del vencimiento del plazo de ejecución contractual (sin que se hayan culminado las prestaciones pactadas), las denominadas "*Otras penalidades*" tienen otros requisitos, que pueden considerarse como las siguientes:

- Deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación.
- Deben estar contempladas en los documentos del procedimiento de selección (Bases), es decir, debe tratarse de supuestos debidamente tipificados.
- No pueden referirse a supuestos ya contemplados en la penalidad por mora (pues de otro modo se estaría penalizando dos veces un mismo hecho).
- Debe establecerse la forma de cálculo.
- Debe contemplarse el ***procedimiento*** por el cual se verifica el supuesto a penalizar.

9.59. En esa misma línea se pronuncia la Dirección Técnica Normativa del OSCE cuando en su Opinión N°052-2022/DTN del 14 de julio de 2022, en cuyo acápite 2.3.1 segundo párrafo, se establece de modo explícito que:

> *"Sin perjuicio de ello, es importante recalcar que para la correcta aplicación de las penalidades distintas a la penalidad por mora ("otras penalidades") la Entidad deberá: i) prever que dichas penalidades sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación; ii) definir los supuestos que originarían su aplicación,*

los cuales deben ser diferentes al retraso injustificado o mora previsto en el artículo 162 del Reglamento; iii) delimitar la forma de cálculo de la penalidad para cada uno de los supuestos que previamente hubiera definido; y, iv) establecer el procedimiento a través del cual verificará si se constituye el supuesto que da lugar a la aplicación de la penalidad."

(El subrayado corresponde al texto original)

9.60. Dicho de otro modo, la determinación sobre la pertinencia de una "Otra penalidad" no se efectúa de modo inmediato, sino que requiere de la instauración previa de un procedimiento, solo luego del cual podrá concluirse en la pertinencia o no, de su imposición. Como en todo procedimiento que lleva consigo la imposición de una medida gravosa para el administrado, en este caso el contratista, se requiere necesariamente que se otorgue al potencial afectado, el debido derecho de defensa.

9.61. En esa misma línea la segunda conclusión de la citada Opinión N°052-2022/DTN es clara cuando indica lo siguiente:

> *"Si en los documentos del procedimiento de selección no se ha contemplado el procedimiento a seguir para verificar la configuración del supuesto que dará lugar a la aplicación de "otras penalidades", dicha penalidad no podrá ser aplicada al contratista."*

9.62. De este modo, el régimen de "Otras penalidades" no corresponde a una única conducta, sino a un conjunto de acciones (u omisiones), definidas únicamente por negación, es decir por ser distintas a la simple medición del atraso o demora en el Contrato.

Su regulación es efectuada en artículo 133° del Reglamento, siendo que, en función a su propia naturaleza heterogénea, requiere de un conjunto de requisitos necesarios para su aplicación, cuyo objeto es efectuar un seguimiento en la conducta del contratista durante la ejecución del contrato, de modo tal que ante cualquier potencial incurrencia de los hechos previamente tipificados, se instaure el respectivo procedimiento para determinar la pertinencia o no de su penalización.

9.63. Al respecto, de una revisión del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases integradas – que forman parte integrante del Contrato – se advierten un total de catorce (14) supuestos tipificados que corresponderían a la aplicación de "Otras penalidades". Tales supuestos se incrementan a un total de veintiún (21) en la Cláusula Décima Tercera del Contrato N°090-2022-MDT/GM propiamente dicho.

En las Bases, para todos los casos, en el rubro "*Procedimiento*" se contempla lo siguiente: "*Según informe del Inspector y/o Supervisor Obra y/o Coordinador y Administrador de Obra*". Por su parte, en el contrato propiamente dicho, en el rubro "*Procedimiento*" el texto varía – para todos los casos – al siguiente: "*Según informe del Supervisor de Obra y/o Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano*".

9.64. El Contratista, en su escrito de demanda, cuestiona la legalidad de tales "Otras penalidades" las que considera que no son razonables ni congruentes, como también el no haberse establecido un debido procedimiento, específicamente, por cuanto se impusieron sin que exista una relación de inmediatez entre la imputación de su ocurrencia y sin haber corrido traslado ni dada a su parte la oportunidad de ejercer su derecho de defensa – es decir – sin que se haya instaurado el procedimiento correspondiente.

9.65. Sobre este tema, la Entidad sostiene que su decisión de imponer "Otras penalidades" por la suma de S/214,068.20 se encuentra sustentada en la Carta N°013-2023-WARI emitida por el representante legal de la empresa supervisora del 16 de febrero de 2023, así como en los informes N°021-2023-MDT/SGIDU-SFLL del 27 de febrero de 2023 y N°034-2023-MDT/SGIDU/JLPS del 06 de junio de 2023, ambos emitidos por la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Totos. Agrega que, para tales efectos, se siguió lo establecido en la Opinión Legal N°011-2023-MDT/ALE/PJT del 12 de junio del 2023, emitido por el Asesor Legal Externo de la Municipalidad Distrital.

Asimismo, sostiene que no habría afectado el derecho de defensa del Contratista, puesto que le habría informado de su decisión de imponer tales "Otras penalidades" mediante la Carta N°053-2023-2023-MDT-GM/RTM del 17 de mayo de 2023.

9.66. Para resolver este tema, debemos preguntarnos si en las Bases – o incluso en el Contrato - se establecieron las condiciones necesarias para la validez de la imposición de las denominadas "*Otras penalidades*", máxime si a simple vista podemos advertir una evidente diferencia entre el número y supuestos contemplados en tales Bases, respecto a las contempladas en el documento contractual propiamente dicho, así como entre la definición del denominado "Procedimiento".

Sobre este último punto, es decir sobre la definición del denominado "Procedimiento" respecto al cual las Bases lo establecen como "*Según informe del Inspector y/o Supervisor Obra y/o Coordinador y Administrador de Obra*", mientras que el Contrato se refiere a este como "*Según informe del Supervisor de Obra y/o Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano*"; advertimos que la diferencia no es sustancial y, en estricto, se trata únicamente de una precisión respecto de quienes debían emitir los referidos sustentos.

9.67. Lo que sí es sustancial es determinar si tales informes, tanto del Supervisor de Obra como de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, pueden ser considerados como un "Procedimiento".

9.68. Al respecto, cabe preguntarnos si puede calificarse como "Procedimiento" al informe o informes de una entidad o, en todo caso del supervisor. Dicho de otro modo ¿Se puede sostener que un informe es sinónimo de un procedimiento?

9.69. El artículo 29° del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General define como procedimiento administrativo al "(…) *conjunto de actos y diligencias tramitados en las entidades, conducentes a la emisión de un acto administrativo que produzca efectos jurídicos individuales o individualizables sobre intereses, obligaciones o derechos de los administrados*."

De ello, queda claro que un informe puede ser el inicio o el fin de un procedimiento (administrativo), pero nunca puede identificarse con el procedimiento en sí mismo.

9.70. Del mismo modo, no puede dejarse de lado el simple hecho que el objeto de tal procedimiento de imposición de "Otras penalidades" tiene como finalidad la imposición de una carga (económica) al respectivo contratista, de modo tal que resulta necesario que antes de la imposición de tal decisión, se haya conferido a quien estará obligado a soportarla, el ejercicio de su respectivo derecho de defensa, como parte de su derecho al debido procedimiento administrativo.

9.71. De los hechos del caso y de la documentación aportada por las partes, queda claro que no ha existido – en forma previa a la decisión de la Entidad de imponer "Otras penalidades" el traslado de las imputaciones a su contraparte, a efectos que este tenga la opción de levantarlas, refutarlas o, bajo cualquier otro escenario, sustentar los motivos por los cuales – en su consideración – no se darían los puestos contemplados en los artículos 161° y 163° del Reglamento para su imposición.

Por el contrario, del propio dicho de la Entidad efectuado en su contestación de la demanda, se advierte que fue recién mediante su Carta N°053-2023-2023-MDT-GM/RTM del 17 de mayo de 2023, luego de tres meses de resuelto el Contrato, que comunicó la imposición de tales "Otras penalidades". Más aún, se advierte con toda claridad que tal comunicación, no corresponde a un traslado previo a una decisión (de penalizar), sino por el contrario, a un hecho dado – es decir el de imponer un conjunto de "Otras penalidades" luego de resuelto el Contrato, sin que ***previamente*** se le haya otorgado a la contraparte el correspondiente derecho de defensa.

9.72. Sin embargo, los informes y la opinión legal no fueron remitidos a la empresa Contratista en aras de una posible subsanación atendiendo al debido procedimiento, y es que recién con la carta N°53, se comunicó al demandante sobre la aplicación de otras penalidades, siendo que la misma precisaba el cobro de estas al termino de ejecución y pago de la valorización correspondiente.

9.73. En tal sentido, ante la inexistencia de un procedimiento propiamente dicho (dada la falta de identidad entre informe y procedimiento) y, conforme todo lo antes expuesto, no se han dado las condiciones que permitan a la Entidad imponer a su contraparte, válidamente, las denominadas "Otras penalidades", motivo por el cual la Cuarta Pretensión Principal del Contratista deviene en **FUNDADA**, en los términos siguientes:

*"Declarar **FUNDADA** la Cuarta Pretensión Principal de la demanda y, por su efecto, determínese que corresponde inaplicar las otras penalidades dispuestas por la Entidad por el monto de S/ 214,068.20 (doscientos catorce mil sesenta y ocho con 20/100 soles), disponiéndose el reembolso de dicho monto en caso de que se hubiera procedido a su cobro."*

10. COSTOS Y COSTAS PROCESALES

10.1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 70º de la Ley de Arbitraje, el Tribunal deberá fijar en el laudo los costos del arbitraje, comprendiendo –entre otros- los honorarios y gastos del Tribunal Arbitral, los honorarios y gastos del secretario, y los gastos razonables incurridos por las partes para su defensa en el arbitraje, así como la parte que deberá asumirlas. Este pronunciamiento del árbitro es obligatorio aun cuando no haya sido expresamente solicitada por las partes como parte de sus pretensiones.

10.2. Sobre el particular, el artículo 73 de la Ley de Arbitraje dispone que el Tribunal Arbitral tendrá en cuenta a efectos de imputar o distribuir los costos del arbitraje, el acuerdo de las partes. A falta de acuerdo, los costos del arbitraje serán de a cargo de la parte vencida.

10.3. Sin embargo, el Tribunal Arbitral podrá distribuir y prorratear estos costos entre las partes, si estima que el prorrateo es razonable, teniendo en cuenta las circunstancias del caso.

10.4. Teniendo como referencia el artículo 70 de la Ley de Arbitraje, los costos arbitrales comprenden:

(i) Los honorarios y gastos del Tribunal Arbitral (determinados por el Centro);
(ii) Los gastos administrativos del Centro;
(iii) Los gastos razonables incurridos por las partes para su defensa en el arbitraje, de haber sido debidamente solicitado;
(iv) Los gastos y honorarios de los peritos o de cualquier otra asistencia requerida por el Tribunal Arbitral;
(v) Los demás gastos razonables originados en las actuaciones arbitrales.

10.5. En el presente caso, el Tribunal Arbitral ha analizado los temas en controversia, estableciéndose que no existe una parte perdedora ni una ganadora, habiendo tenido ambas razones suficientes para litigar, de modo tal que la controversia suscitada entre las partes solo ha podido ser dilucidada con motivo del presente Laudo.

10.6. Considerando que en este caso se han dado resultados mixtos y, asimismo, teniendo en cuenta la adecuada conducta procesal de ambas partes, corresponde que cada parte asuma los propios costos en los que hubiera incurrido en su respectiva defensa.

10.7. Asimismo, teniendo en cuenta que, durante el presente proceso arbitral, se establecieron liquidaciones separadas, corresponde a la parte demandante asumir las que se han asignado como a cargo de su parte.

11. DECISIÓN

11.1. Finalmente, el Tribunal Arbitral deja constancia que para la expedición de este laudo ha analizado todos los argumentos de defensa expuestos por las partes y ha examinado cada una de las pruebas aportadas por éstas de acuerdo a las reglas de la sana crítica y al principio de libre valoración de la prueba y que el sentido de su Decisión es el resultado de ese análisis y de su convicción sobre la controversia, al margen de que algunas pruebas presentadas o actuadas y algunos de los argumentos esgrimidos por las partes no hayan sido expresamente citados en el presente laudo, habiendo tenido también presente durante la tramitación de todo este proceso arbitral y en las expediciones de este laudo, los principios que orientan y ordenan todo arbitraje y que fueron consignados en el Acta de Instalación del Tribunal Arbitral.

11.2. Estando a las consideraciones expuestas, dentro del plazo correspondiente, el Árbitro Único**,** en derecho,

RESUELVE:

PRIMERO: Declarar **FUNDADA** la Primera Pretensión Principal de la demanda y, por su efecto, determínese que corresponde declarar la nulidad, invalidez e ineficacia de la Resolución de Gerencia Nº006-2023-MDT/GM, por medio de la cual la ENTIDAD resolvió el Contrato Nº090-2022-MDT/GM.

SEGUNDO: Declarar **INFUNDADA** la Segunda Pretensión Principal de la demanda y, por su efecto, determínese que no corresponde declarar que el avance parcial establecido en el calendario de avance de obra vigente es mayor al 80% del monto de la valorización acumulada programada a enero de 2023.

TERCERO: Declarar **INFUNDADA** la pretensión subordinada a la Segunda Pretensión Principal de la demanda y, por su efecto, determínese que no corresponde declarar que el avance menor al 80% del calendario de obra vigente, se encuentra justificado en acontecimientos o hechos no atribuibles a la empresa.

CUARTO: Declarar **INFUNDADA** la Tercera Pretensión Principal de la demanda y, por su efecto, determínese que no corresponde declarar que la obra se encontraba paralizada y el contrato suspendido para todos sus efectos por el período comprendido entre el 01 al 24 de febrero de 2023.

QUINTO: Declarar **FUNDADA** la Cuarta Pretensión Principal de la demanda y, por su efecto, determínese que corresponde inaplicar las otras penalidades dispuestas por la Entidad por el monto de S/ 214,068.20 (doscientos catorce mil sesenta y ocho con 20/100 soles), disponiéndose el reembolso de dicho monto en caso de que se hubiera procedido a su cobro.

SEXTO: Declarar que corresponde a cada parte asumir los propios costos en los que hubieran incurrido en el presente caso arbitral, asimismo teniendo en cuenta que en el presente caso se establecieron liquidaciones separadas, corresponde a la parte demandante asumir las que se han asignado como a cargo de su parte.

SÉPTIMO: DISPÓNGASE que se publique el presente Laudo Arbitral en el SEACE.

Notifíquese a las partes.

MARCO ANTONIO MARTÍNEZ ZAMORA
ÁRBITRO ÚNICO

Resolución N° 20

Lima, 26 de febrero de 2024

I. VISTOS:

i) Solicitud Cautelar de fecha 30 de octubre de 2023 presentado por HIDROCONSULTING INGENIEROS ASOCIADOS S.R.L.
ii) Resolución Cautelar N°04 de fecha 14 de diciembre de 2023 presentado por el Árbitro Único.
iii) Resolución Cautelar N°06 de fecha 12 de enero de 2024, emitida por el Árbitro Único.
iv) Resolución N°18, que corresponde al Laudo arbitral del EXP N°05-2023-MAMZ-CARD-CECARD/AYA emitido por el tribunal arbitral de Arbitro Único.
v) La Carta N°09-2024-MDT/GM de la Municipalidad distrital de Totos (ahora en adelante la Entidad) de sumilla "INTERPRETACIÓN DE LA PARTE DECISORIA DEL LAUDO ARBITRAL" mediante escrito con fecha 24 de enero de 2024;
vi) Escrito del Contratista HYDROCONSULTING Ingenieros Asociados S.R.L (en adelante el Contratista) con sumilla: "ABSOLVEMOS SOLICITUD DE INTERPRETACIÓN DE LAUDO" con fecha 12 de febrero de 2024

CONSIDERANDO:

II. SOBRE LA SOLICITUD PRESENTADA

2.1. La Entidad presentó una solicitud de interpretación alegando que extremos de la motivación del primer punto resolutivo del Laudo Arbitral, devienen en oscuros, imprecisos o dudosos; respecto de la primera pretensión declarada fundada por el Tribunal Arbitral en favor de la parte Demandante, declarándose nula la Resolución Gerencial N°006-2023-MDT/GM por la cual se resolvió el Contrato N°090-2022-MDT/GM:

> ***Primera pretensión principal:*** *Que se declare la Nulidad, Invalidez e Ineficacia de la Resolución de Gerencia N°006-2023-MDT/GM por la cual la Municipalidad de Totos resolvió el Contrato N°090-2022-MDT/GM.*

2.2. Sobre el tema, la Entidad sostiene que no se advierte en la decisión arbitral, cuál será el estado situacional de la empresa HIDROCONSULTING, en su condición de parte demandante, específicamente respecto a la obra materia del Contrato: "*MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PIEDRA BLANCA – WICHINKA EN EL CENTRO POBLADO DE CHACABAMBA-TOTOS-CANGALLO-AYACUCHO*", en cuanto la Entidad ya celebró contrato con otra empresa denominada Consorcio SAN JOSE, para el saldo de obra.

2.3. Respecto a ello, el Contratista mediante su escrito de absolución de la solicitud de interpretación presentada por la Entidad, alega que la misma no es materia de interpretación por el Tribunal Arbitral, en cuanto, no hay extremo oscuro o dudoso en la resolución de la controversia, puesto que

el primer punto resolutivo del Laudo responde pertinentemente al primer punto controvertido (objeto de la solicitud de interpretación) correspondiendo su naturaleza declarativa, al igual que la primera pretensión demanda.

2.4. Por otro lado, afirma el Contratista que la Entidad pretende que el Tribunal le dé pautas o instrucciones de como debería actuar frente la nueva vigencia del Contrato N°090-2022, no correspondiendo ello a una solicitud de aclaración de laudo.

III. MARCO CONCEPTUAL

3.1. Antes de iniciar el análisis de la solicitud de interpretación, planteada por la Entidad, el Árbitro considera pertinente delimitar brevemente el marco conceptual del recurso.

3.2. En lo que respecta a la interpretación o aclaración de laudo, el artículo 58º inciso b) de la Ley de Arbitraje (Decreto Legislativo N°1071) contempla el recurso de interpretación:

> *"1. Salvo acuerdo distinto de las partes o disposición diferente del reglamento arbitral aplicable:*
> *(…)*
> *b) Dentro de los quince (15) días siguientes de la notificación del laudo, cualquiera de las partes puede solicitar la interpretación de algún extremo oscuro, impreciso o dudoso expresado en la parte decisoria del laudo o que influya en ella para determinar los alcances de la ejecución"*

3.3. Por tal, de acuerdo con la Ley de Arbitraje, compete aclarar o interpretar algún extremo dudoso, en la parte resolutiva del laudo (parte decisoria) y, excepcionalmente, la parte considerativa en cuanto influya en ella.

3.4. La doctrina arbitral es estricta al calificar las facultades de los árbitros de aclarar su laudo. Así, de un lado, tenemos que HINOJOSA SEGOVIA señala lo siguiente:

> *"Debe descartarse de principio que la aclaración sirva para resolver cuestiones esenciales que no hayan sido objeto de debate. En otras palabras, la aclaración del laudo no puede tener un contenido que desvirtúe su función; así, pues, <u>ha de venir referida únicamente a la corrección de errores materiales o a la aclaración de conceptos oscuros u omisiones (y nunca a resolver cuestiones sustanciales de puntos que hayan sido objeto de controversia)</u>. El laudo que incurra en el vicio de la oscuridad, no cumple su fin, puesto que no queda decidida sin duda la controversia"* [1]. El subrayado es nuestro.

3.5. Similarmente, CRAIG, PARK y PAULSSON señalan sobre este tema puntual que:

---

[1] HINOJOSA SEGOVIA, Rafael. "El recurso de anulación contra los laudos arbítrales (Estudio jurisprudencial)". Editorial Revista de Derecho Privado – Editoriales de Derecho Reunidas S.A. Madrid, 1991, pp. 336 y 337.

> *"El propósito de la norma es permitir la aclaración de un laudo para permitir su correcta ejecución (como, no puede ser usada para requerir al Tribunal que explique, o que reformule, sus razones. Ésta no provee una ocasión para que el Tribunal reconsidere su decisión, por ejemplo, si pareciera haber mandatos en conflicto en la parte operativa del laudo). Ésta. Si esa fuera la base de la solicitud de la parte, el Tribunal tendría fundamentos de sobra en encontrar como innecesario o inapropiado el conceder la «interpretación» requerida"*[2]

3.6. Como explican los citados autores, esta facultad (la de aclarar un laudo), tiene como propósito permitir la correcta ejecución del laudo arbitral; por ejemplo, cuando en la parte decisoria existen órdenes contradictorias. En virtud a ello, no es factible que las partes utilicen este recurso para solicitar a los árbitros que expliquen los argumentos que aparecen en los considerandos del fallo.

3.7. Ello coincide con lo que bien explica el doctor Cantuarias Salaverry[3]:

> *"La aclaración tiene como propósito que se aclare, valga la redundancia, el laudo arbitral, a efectos de permitir su correcta ejecución; por ejemplo, cuando en la parte resolutiva parece que existen órdenes contradictorias, Por lo tanto, no cabe que las partes apelen a este remedio para pretender que los árbitros les expliquen la parte considerativa del laudo y menos para que reformulen su razonamiento, ya que la aclaración no es sinónimo de reconsideración."*.

3.8. Entonces, dicho recurso no busca explicar los motivos de la decisión tomada, ni mucho menos modificarla, re fundamentar la posición de una de las partes o plantear una reevaluación de los hechos, con miras a la variación del resultado; sino que buscan aclarar al solicitante sobre algún extremo que genere confusión, con el fin de garantizar la ejecución del Laudo arbitral.

IV. **ANÁLISIS EN ESPECIFICO**

4.1. Con fecha 12 de enero del 2024, mediante decisión N°18, el Tribunal arbitral de Arbitro Único emitió el Laudo de Derecho que resuelve las controversias suscitadas entre el Contratista y la Entidad respecto a la ejecución de la obra: "*MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PIEDRA BLANCA – WICHINKA EN EL CENTRO POBLADO DE CHACABAMBA, DISTRITO DE TOTOS, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO" CÓDIGO SNIP UNIFICADO N° 2317199"*

4.2. Como resultado de dicho Laudo Arbitral, se declaró FUNDADA la primera pretensión principal de la demanda antes mencionada, de la siguiente manera:

---

[2] W. LAURENCE CRAIG, WILLIAM W. PARK & JAN PAULSSON. "International Chamber of Commerce Arbitration". Oceana Publications Inc., 3ra. Ed., 2000, p. 408.

[3] CANTUARIAS SALAVERRY, Fernando, en "Arbitraje comercial y de las inversiones". Editora Jurídica Grijley E.I.R.L. Año 2007. Pág. 148

Lo solicitado

Primera pretensión principal: *Que se declare la Nulidad, Invalidez e Ineficacia de la Resolución de Gerencia N°006-2023-MDT/GM por la cual la Municipalidad de Totos resolvió el Contrato N°090-2022-MDT/GM.*

Lo resuelto

PRIMERO: *Declarar* ***FUNDADA*** *la Primera Pretensión Principal de la demanda y, por su efecto, determínese que corresponde declarar la nulidad, invalidez e ineficacia de la Resolución de Gerencia N°006-2023-MDT/GM, por medio de la cual la ENTIDAD resolvió el Contrato N°090-2022-MDT/GM.*

(Los subrayados son nuestros)

4.3. Teniendo en cuenta ello, como bien, se ha consignado en el marco conceptual, el recurso de aclaración de laudo sirve para despejar dudas a la parte solicitante, respecto a algún punto confuso, oscuro o contradictorio de la decisión arbitral que no pudiese entenderse respecto de la decisión adoptada en el laudo, específicamente en la parte resolutiva y, sólo por excepción, en la parte considerativa – cuando la decisión se remite a ella.

4.4. Por ello, considera el Árbitro Único que, si bien la solitud formulada por la Entidad no constituye un pedido impugnatorio contra el laudo arbitral; No hay extremo oscuro ni confusión alguna suscitada en el primer punto resolutivo (sobre la declaración de nulidad de la Resolución de Gerencia N°006-2023-MDT/GM, por medio de la cual la ENTIDAD resolvió arbitrariamente el Contrato) que amerite recurso de aclaración de Laudo; en cuanto el mismo ha sido bien explicado en los acápites 9.6. al 9.26. del segmento IX de ANÁLISIS del Laudo Arbitral, siendo así que, la decisión de resolución del contrato fue declarada nula, invalida e ineficaz; y declarada fundada la Primera pretensión principal de la demanda arbitral.

Dicho de otro modo, queda claro que la decisión de la Entidad de resolver el contrato imputando responsabilidad a su contraparte, ha quedado sin efecto.

4.5. Debe tenerse presente que el Árbitro Único no puede resolver cuestiones que no han sido planteadas en la demanda o en la reconvención – en caso esta hubiera sido presentada, siendo que la controversia que motiva el pedido de interpretación estaba referida únicamente a la pertinencia de la decisión de la Entidad de resolver el Contrato por causa imputable al Contratista, tema el cual ha sido específicamente resuelto, determinándose que esta no se encontraba ajustada a derecho y, por ende, quedaba sin efecto, con todo lo que ello implica.

No correspondía al Laudo Arbitral emitir pronunciamiento sobre hechos posteriores – tales como la situación del contrato del saldo de obra – pues

no correspondía al petitorio y, por ende, a los puntos controvertidos sobre los cuales correspondía emitir pronunciamiento.

4.6. No debe confundirse la decisión que correspondía adoptar al árbitro al resolver las controversias en el Laudo Arbitral, con lo decidido respecto de la solicitud de medida cautelar efectuada por el Contratista y en el pedido de reconsideración planteado por dicha parte con la decisión adoptada sobre tal incidente. Debe recordarse que las medidas las medidas cautelares tienen una finalidad meramente provisional y, bajo ningún concepto, generan cosa juzgada u otra medida que pudiese considerarse bajo una forma u otra, como definitiva.

4.7. Así las cosas, la medida cautelar solicitada por el Contratista fue desestimada únicamente por cuanto, a consideración del Árbitro Único no se puede negar a una entidad la potestad de contratar el saldo de obra de un contrato previamente resuelto, tal como expresamente lo establece el artículo 167° numeral 1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la Entidad puede actuar según le convenga respecto al saldo no ejecutado sin necesidad de tener una decisión final por parte de un Tribunal:

> "*167. Prestaciones pendientes en caso de resolución de contrato o declaratoria de nulidad de contrato: 1.- Cuando se resuelva un contrato o se declare su nulidad y exista la necesidad urgente de continuar con la ejecución de las prestaciones derivadas de este, sin perjuicio de que dicho acto se encuentre sometido a alguno de los medios de solución de controversias* (…)"

Ello no implica que la respectiva entidad tenga la opción contraria, es decir, la de esperar la decisión que se adopte en sede arbitral, cuando existe una controversia en trámite.

4.8. Tampoco puede considerarse que el ejercicio de la posibilidad de contratar el saldo de obra libere a una entidad de la responsabilidad por la decisión que adopta. Tal como hemos visto, posibilidad no es sinónimo de obligación, de modo tal que – al igual que toda decisión de gestión que se adopte, quien ejerza la opción debe asumir sus consecuencias, tanto en sus vertientes positivas, como respecto de los inconvenientes o problemas posteriores que pudiesen suscitarse.

En tal sentido, no existe contradicción alguna entre denegar un pedido cautelar por el que se desestime ordenar la suspensión de la contratación de un saldo de obra, en este caso la convocada por el procedimiento de selección N°002-2023-MDT/CS y, por el otro, resolver que la resolución del contrato efectuada en perjuicio del demandante quedaba sin efecto, como ha ocurrido en el presente caso.

4.9. En línea con todo lo anterior, no es parte del Laudo Arbitral y, por ende, no cabe interpretación sobre aquello que no era de su competencia, la situación posterior a la decisión con rango de cosa juzgada adoptada por el Árbitro Único, en cuanto a la fecha se encontrarían vigentes tanto

el contrato original suscrito entre la Municipalidad Distrital de Totos y la empresa HIDOROCONSULTING, como el contrato por el saldo de obra suscrito entre dicha misma Entidad y el Consorcio San José.

En tal sentido, corresponderá a las partes, en vía de ejecución del Laudo Arbitral, adoptar las medidas o acuerdos que resulten pertinentes, para un adecuado o debido cierre del Contrato suscrito con el actual demandante, teniéndose en cuenta que no existió hecho imputable que hubiera justificado la decisión de la decisión de resolver el vínculo contractual con HIDROCONSULITNG, habiéndose dejado sin efecto la decisión de la Entidad en este extremo.

4.10. Por lo cual, mediante la presente Resolución se consigna que, NO HAY extremo oscuro y/o confuso en el primer punto resolutivo que devenga en que la Entidad incurra en incumplimiento de la decisión arbitral, respecto a lo dispuesto en el primer punto resolutivo, en cuanto la decisión arbitral responde pertinentemente a la primera pretensión de la demanda/primer punto controvertido.

Asimismo, no es objeto de un pedido de aclaración, el consignar pautas de actuación posteriores a la emisión del Laudo Arbitral, respecto al estado situacional de la obra y sobre como ha de actuar la Entidad para cumplir con lo laudado, teniendo en cuenta la vigencia de los contratos suscritos con HYDRONSULTING y del Consorcio SAN JOSE, conforme todo lo antes mencionado.

SE RESUELVE:

PRIMERO: Declarar INFUNDADO el pedido de aclaración de laudo arbitral efectuado por la Entidad, conforme a los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO: Declárese que la presente resolución forma parte integrante del Laudo Arbitral.

Notifíquese,

MARCO ANTONIO MARTÍNEZ ZAMORA
ÁRBITRO ÚNICO